

De lo planteado en los textos legales transcritos para ejemplificar, surge con meridiana claridad, que el ordenamiento jurídico tiende a brindarle al hombre determinadas seguridades. Si actúa conforme a él, sus actos están protegidos por la sociedad en su conjunto.

Si una persona adquiere la propiedad de algo, de acuerdo a la forma y el modo que prescribe el Derecho, la sociedad en su conjunto, y los órganos del Estado lo protegen en el ejercicio regular del derecho de propiedad.

Cualquier persona goza del derecho, frente a la presunta comisión de un hecho ilícito, a ser juzgado por sus jueces naturales, y sólo por leyes anteriores al hecho que pretende ser juzgado.

Las acciones privadas de los hombres son ajenas al orden jurídico y están protegidas por todo el ordenamiento para el pleno disfrute de las mismas, con el único límite impuesto por el respeto a los derechos presentes en los terceros.

Si una persona celebra un contrato, tiene la seguridad de su cumplimiento y, en caso de que la otra parte comprometida en el convenio incumpliera, podrá optar por poner en movimiento la maquinaria judicial que obligue al incumplidor al fiel desarrollo de la palabra empeñada.

En resumen, el hombre, por su particular naturaleza pretende garantizar su vida —en el más amplio sentido— más allá de lo que el mañana le depare. Para ello sabe que cuenta con el Derecho.

La permanencia de las disposiciones jurídicas también coadyuva a esta finalidad de seguridad. Hemos dicho que es contradictorio con el Derecho los cambios cotidianos, por eso la norma jurídica una vez formulada tiene vocación de eternidad. Lo que hoy está dispuesto legalmente mañana también lo estará.

"La seguridad jurídica supone que derechos, posiciones de poder y de posesión una vez fundadas, tienen que subsistir sin que nadie las discuta ni perturbe, y que las decisiones jurídicas, una vez formulada, deben ser mantenidas. Al servicio de la seguridad jurídica están todas las instituciones que precisan y mantienen los derechos existentes, como los registros públicos, la exigencia de escritura, etcétera... En la seguridad del Derecho se basa en gran parte su benéfica acción. El hombre aspira siempre a crear instituciones y situaciones duraderas bajo cuya protección puede vivir, el hombre quiere sustraer su existencia a un cambio permanente, dirigirla por vías seguras y ordenadas y librarse del asalto constante de lo nuevo. El Derecho tiene que ofrecerle esta certeza, esta calculabilidad" ¹¹.

¹¹ COING, H., *Fundamentos...*, cit., págs. 39/40.

Obsérvese que en las nuevas situaciones que pueden presentarse en una sociedad, los órganos jurisdiccionales se esfuerzan por aplicar las viejas normas. Hemos dicho que lo único que permanece constante en el devenir histórico del hombre es su propia evolución, motorizada por la permanente búsqueda de formas más justas de convivencia. El hombre diariamente evoluciona, y con él la sociedad. El Derecho debe lograr, también en forma cotidiana, cierta adecuación a estas nuevas situaciones, sin que por ello afecte la seguridad y permanencia del orden jurídico. *"Lo que subsiste durante mucho tiempo tiene para el hombre un carácter de seguridad digna de confianza, y es precisamente aquello que busca el Derecho. Cuanto más duradera es la persistencia de un derecho, tanto más capaz será de realizar su tarea de dar seguridad jurídica, tanto más seguros se sentirán los hombres bajo su protección"* ¹².

La jurisprudencia ha aportado en este aspecto, al lograr aplicar la vieja norma sin que ello resulte repugnante al estadio de evolución correspondiente a la sociedad de ese momento. Esto permite adecuar el viejo texto legal a la convicción de justicia que se haya alcanzado en ese estadio concreto. Evitando de esta manera dos graves males que pueden afectar al orden jurídico. Uno, los excesivos cambios, el otro la cristalización que le impide adecuarse armónicamente a la evolución.

Para ejemplificar vamos a analizar el avance de la doctrina del abuso del Derecho en nuestro ordenamiento jurídico.

El abuso del Derecho se configura cuando en el ejercicio de un derecho propio se actúa en contra de los fines económicos y sociales que inspiraron la norma que los otorga, y también cuando este ejercicio lo es contra la moral y la buena fe. Es decir, hay abuso del derecho cuando una persona en el ejercicio de su derecho elige innecesariamente el camino más gravoso para la otra parte.

En nuestra legislación positiva, en el artículo 1071 del Código Civil, se disponía: "El ejercicio de un derecho propio, o el cumplimiento de una obligación legal, no pueden constituir como ilícito ningún acto". Pese a la aparente rigidez del texto legal transcrito, la jurisprudencia lentamente fue abriendo un camino para la doctrina del abuso del derecho. Hasta que la reforma constitucional de 1949 la disponía expresamente en su artículo 35: "Los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero tampoco amparan a ningún habitante de la Nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de esos derechos que perjudiquen a la co-

¹² COING, *Fundamentos...*, cit., pág. 40.

munidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que serán castigados por las leyes".

Con la citada reforma, esta doctrina que se venía aplicando tímidamente por los tribunales, consolidó su posición: *"La derogación de esta reforma no alteró mayormente el rumbo. Por lo pronto, la Suprema Corte declaró que la teoría del abuso del derecho tiene vigencia en nuestro derecho positivo con prescindencia del precepto constitucional que lo consagraba (fallo del 18-IV-1956). Y los tribunales han seguido aplicando el concepto de que los derechos no pueden ejercerse abusivamente. Así, por ejemplo, se ha declarado que incurre en abuso del derecho el acreedor que elige inútilmente la vía más gravosa para el ejecutado; el marido que luego de treinta años de separación, intima a su esposa que se reintegre al hogar para liberarse de la prestación de alimentos, si aquélla, como era de esperar, se negare a reintegrarse; si se pretende reivindicar una franja de pocos centímetros sobre los cuales el vecino había edificado"*¹³.

Este esfuerzo de la judicatura por adecuar el rígido texto legal a las íntimas convicciones de justicia que anidan en la conciencia jurídica obtuvo —en este caso— plena consagración legislativa con la ley 17.711, que modificó el Código Civil y, entre otros, el artículo 1071, que quedó redactado de la siguiente manera: "El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contrarie los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres".

Para comprender cabalmente este enorme esfuerzo, corresponde situarnos en el momento en que se realizó. La rígida legislación vigente (la Constitución Nacional y el Código Civil) tenía un neto corte individualista, conforme al momento en que se redactó, sin embargo, los jueces encontraron el camino para dictar sus sentencias, sin contradecir las convicciones jurídicas del momento histórico en que actuaron.

En otro orden de ideas, el instituto de la cosa juzgada también es un claro ejemplo del importante privilegio que todo el ordenamiento jurídico concede a este objetivo de seguridad.

Para finalizar, la seguridad del orden jurídico requiere que aquello que está dispuesto legalmente tenga la protección de la sociedad en su conjunto, y de sus órganos especializados, y que las modificaciones que eventualmente puedan surgir, no afecten los derechos que ya se encuen-

¹³ BORDA, G., *Derecho...*, cit., pág. 33.

tran consolidados. Todo ello con el límite impuesto por el ejercicio regular de los derechos que las leyes otorgan.

Hemos analizado la finalidad de paz y seguridad. Estos objetivos sugieren algunas coincidencias con órdenes ajenos, y a veces contradictorios con el Derecho, por lo que muchos autores los han confundido.

*"El Derecho se apoya en una autoridad social; el Derecho necesita, para ser perfecto, el poder que se ponga a su servicio. Pero, por otra parte, como el Derecho está a su vez al servicio de lo existente, la relación entre el poder y el Derecho se invierte fácilmente, y no es el poder que sirve al Derecho, sino el Derecho el que conserva ante todo las relaciones de poder existentes. Orden, paz, seguridad, no sólo son rasgos esenciales del Derecho, sino también pueden ser intereses del poder... Siempre existe el peligro de que el orden jurídico se convierta en instrumento de los poderosos, el peligro, esto es, de que el Derecho no sancione más de lo que los poderosos deseen... Y no se trata de pretensiones arbitrarias bajo la presión del poder, sino de que los intereses de los poderosos se impongan ya en la elaboración misma del Derecho antes de su aplicación... El hombre espera algo más que orden y seguridad, cualquiera que sea el contenido de éstos. Aunque según la clásica formulación de Goethe, el estado consiste exclusivamente en que la propiedad esté cierta y segura, los hombres se han preguntado siempre además si está poseída con justicia"*¹⁴.

La finalidad del Derecho no sólo es la paz y la seguridad, también integran este concepto la igualdad, la libertad y las exigencias morales del Derecho.

c) Igualdad

El objetivo de igualdad constituye uno de los más profundos deseos del orden jurídico. El concepto de igualdad ante la ley, tan difundido en los últimos siglos, se encarna absolutamente en todos los órdenes jurídicos de los estados modernos.

Nuestra Constitución lo establece expresamente en el artículo 16: "Todos los habitantes son iguales ante la ley".

Sin embargo, este concepto tan declamado, requiere de un prolijo análisis, porque su aplicación lisa y llana puede provocar como resultado un tratamiento discriminatorio y desigual.

En principio, sabemos que no existen ni existieron dos personas iguales. De los millones de millones de hombres que han transitado el pla-

¹⁴ COING, H., *Fundamentos...*, cit., págs. 43/44.

neta, no hubo dos que fueran iguales. De la misma manera sabemos que no existen dos actos o situaciones iguales. Un homicidio jamás es igual a otro, un contrato tampoco. En el primer ejemplo, en ambos casos se produjo la muerte de un hombre, en uno pudo ser el resultado de la acción de un arma de fuego, en el otro por un accidente de tránsito; las posibilidades se multiplican enormemente, y los actores del drama no pueden repetirse jamás. En el segundo ejemplo, un contrato que podría ser de locación de un departamento, nunca es igual a otro, o cambia el objeto, o las partes, o el momento, etcétera, aunque contenga las mismas cláusulas, contiene también elementos diversos de suficiente entidad para reconocer a simple vista que no son iguales.

De esto podemos deducir que la igualdad que alienta el Derecho como finalidad de su acción, no se refiere a una igualdad matemática, que en nuestra materia naturalmente no se da.

La igualdad que pretende el orden jurídico es aquella que descorre el velo de la formalidad para penetrar en la realidad misma de la relación jurídica y proteger a aquél que en esa relación concreta se encuentra en inferioridad, para que la igualdad no sea una mera declamación carente de ulterior eficacia (v.gr., instituto de la capacidad, teoría de la imprevisión, del enriquecimiento ilícito, del abuso del derecho, etc.).

Es necesario resaltar que si afirmamos que todos los hombres son iguales ante la ley y finalizamos allí el planteo, dejamos abierta una enorme brecha por donde pueden filtrarse las más atroces injusticias y abusos. La vida cotidiana nos ofrece innumerables ejemplos en donde las personas se encuentran en una profunda desigualdad, por lo que pretender igualar, sin más, lo desigual, tiene necesariamente como resultado una desigualdad mayor.

No puede ser tratado de igual manera —por el Derecho— el trabajador y el empresario (en lo que respecta al contrato de trabajo y a todas las relaciones que surgen como consecuencia del mismo). No son iguales, más allá del domicilio, la tarea que desarrolle, el color de ojos, etcétera, el que recibió instrucción terciaria y el que es analfabeto.

No planteamos una desigualdad en cuanto a su condición de hombre, ya que tanto el trabajador como el empresario, el analfabeto como el que recibió instrucción, el menor como el mayor de edad, el demente como el sano, etcétera, todos son portadores de la misma dignidad, que surge y se sustenta en la simple condición de ser hombres, pero que en la interrelación que entre ambos pueda realizarse, surgen diferencias objetivas que el orden jurídico debe receptor para garantizar, entonces, el triunfo final de este principio de igualdad.

En última instancia, se garantiza la igualdad, protegiendo a aquel que se encuentra en una relación jurídica concreta en un estado de objetiva inferioridad. Porque la igualdad que alienta el orden jurídico no implica igualar lo objetivamente desigual, sino otorgar herramientas a quien se encuentra en inferioridad en la relación, para que el resultado final de la relación concreta sea lo más igualitario posible, de acuerdo al estadio de evolución de la sociedad de que se trate.

Esta finalidad de igualdad, es uno de los elementos que nos permite distinguir el orden del Derecho, del orden del mero poder estabilizado.

d) Libertad

Una situación que hace absolutamente al hombre es, sin dudas, su libertad. El hombre no se encuentra determinado por el instinto, sino que su libertad, y su voluntad pueden llevarlo a realizar conductas contrarias hasta con sus propios impulsos vitales, en absoluta represión de sus instintos. Esta afirmación es un dato probado y demostrado por distintas ciencias (v.gr., psicología, sociología).

Si no existiera la libertad, no cabría la posibilidad de entender la responsabilidad (si un perro rompe una planta en el jardín, podríamos reprenderlo, castigarlo, atarlo, etc., pero nunca considerarlo responsable de una conducta contraria a la deseada).

El hombre es responsable de sus actos, en la medida en que tenga, a su vez, la posibilidad de elegir entre hacerlo y no hacerlo. Si el hombre se encuentra conminado a realizar una conducta que el orden jurídico considera ilícita, y no puede evitarlo, no podemos, tampoco, acusar a esa conducta responsabilidad alguna. Piénsese en un naufragio, donde una persona que no tiene salvavidas, se lo quita a otra —para salvar su propia vida— lo que provoca que ésta perezca ahogada, y aquél logre llegar a la costa y así, salvar su vida. O, el caso del hurto famélico, que es aquel en que una persona no posee, siquiera, la posibilidad de obtener alimentos para su propia subsistencia, por lo que los hurta. En ambos casos surge con absoluta nitidez la falta de libertad en el obrar de esas personas, por lo que, pese a que las conductas descriptas corresponden a ilícitos, no es posible hablar de responsabilidad alguna.

La libertad es una finalidad esencial de cualquier orden jurídico, porque forma parte de la naturaleza misma del hombre. A tal punto que mientras exista un hombre, éste es esencialmente libre. No es posible quitarle al hombre en términos absolutos su libertad, ya que para ello habría que quitarle la vida. Lo que demuestra que el hombre es portador de su libertad, la que nadie puede afectar totalmente, ya que el espíritu del hombre

puede resistir cualquier vinculación que pretenda imponérsele, a la que sólo puede adherir a partir de su propia voluntad (v.gr., nadie puede obligarme a pensar en determinada manera, o prohibirme hacerlo en tal objeto).

Pese a lo dicho, el Derecho no se conforma con reconocer la existencia de la libertad en sentido filosófico, propio de la naturaleza del hombre; sino que requiere materializar esta potencialidad humana en cuestiones concretas. Nuestra Constitución en los artículos 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19, 32 —entre otros— garantiza ante cuestiones concretas la libertad, atributo esencial de la conducta humana.

El ordenamiento jurídico establece determinadas libertades particulares (de prensa, de trabajo, de testar, de contraer matrimonio, etc.), lo que no debe entenderse como negación de otras libertades, porque éstas son meras exteriorizaciones particulares de lo que podemos llamar, esencialmente, el derecho de libertad (al que algunos autores denominan facultad de señorío), que significa la potestad de realizar o no lo que dispone la facultad jurídica en cabeza de cada uno de los hombres.

Por último, diremos que la norma de libertad (todo lo que no está prohibido, está jurídicamente permitido, art. 19, Const. Nac.) nos plantea, previamente a cualquier regulación, la libertad, como estado previo a la formulación concreta y positiva de los derechos.

*"En efecto, la libertad es la esencia misma de la conducta y de la existencia humana y, para probarlo basta con observar la conducta del hombre y verlo actuar constantemente y guiado por su libre albedrío. Siendo ello así, el Derecho no puede ignorar esa realidad —que es su presupuesto necesario— sin caer en el absurdo y en la ignorancia... El principio de que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido, no significa meramente la disyunción lógicamente convertible de que todo lo que no es ilícito, es lícito (que sin alteración de sentido se puede convertir en su inversa: todo lo que no es lícito es ilícito) sino que en forma inconvertible enuncia la libertad como el prius del Derecho. No se puede decir: todo lo que no está permitido, está jurídicamente prohibido, porque sería enunciar una paralización imposible de la vida... Para concluir este párrafo, cabe expresar sintéticamente que en esa libertad de la conducta —presupuesto necesario del Derecho— se halla el fundamento ontológico de la norma de libertad"*¹⁵

La finalidad del Derecho no se agota en los objetivos de paz, seguridad, igualdad, libertad, sino que el Derecho persigue, también en forma

inclaudicable, la realización de determinados valores morales. Renunciar a este camino es ceder espacio, para que el poder se instale en la sociedad de que se trate, transformando sus normas, paulatinamente, en posiciones de poder, que nada tienen en común con las posiciones de Derecho.

Las exigencias morales del Derecho pueden reducirse a dos: la dignidad del hombre y la justicia.

VI. VALORES A REALIZAR POR EL ORDEN JURÍDICO

Antes de analizar las exigencias morales del Derecho, debemos detenernos sintéticamente en el problema de la axiología jurídica (lo que desarrollaremos con mayor detenimiento en los Caps. IV y V).

Los valores son esencias objetivas, las que el hombre puede captar, conocer, con mayor o menor plenitud, en un todo de acuerdo al estadio de evolución en que se encuentre. La belleza, lo útil, lo bueno, son valores que tienen una existencia en sí. No es el hombre al conocerlos, al captarlos que le otorga valor al valor.

Este tema sobre la objetividad o subjetividad de los valores no es nuevo, desde la antigüedad los filósofos lo discuten. Nosotros no dudamos en afirmar, en contra de las teorías relativistas y nihilistas, la objetividad de los valores, es decir, los valores existen más allá de nuestra subjetividad que los capta. Porque no es un fenómeno psíquico o intelectual del hombre, que al conocer un valor, le otorga a su vez, un tipo particular de existencia en el mundo en que vive, sino que el valor existe con absoluta prescindencia del conocimiento que el hombre tenga de él.

En otras palabras, la esclavitud es mala, sin que importe, para realizar este juicio, que algún o algunos hombres piensen o hayan pensado en algún momento histórico sobre la conveniencia de aquella institución, lo que implica, que no depende de nuestra particular opinión la existencia en sí de los valores, con independencia de nuestra fragmentaria captación de los mismos.

Con lo dicho nos basta, por ahora, para analizar los dos valores centrales del orden jurídico: la dignidad moral del hombre y la justicia, los que se nos revelan como finalidad esencial del Derecho. Esta afirmación, no hace mella con respecto a que la paz, la seguridad, la libertad y la igualdad son, también, valores a realizar por el orden jurídico (sobre esto volveremos en el Cap. IV).

¹⁵ TORRÉ, A., *Introducción...*, cit., págs. 221/222.

a) Dignidad moral del hombre

La dignidad moral del hombre es un dato previo que el Derecho debe recoger. Hemos dicho que el hombre es *"una dignidad en continuo forcejeo y una vocación indeclinable hacia formas superiores de vida"*¹⁶.

Este concepto de dignidad de la persona del hombre, lleva ya varios siglos de paciente elaboración (el Humanismo y el Cristianismo han delineado en el devenir la imagen valorativa del hombre). Reconocer el valor inmenso, absoluto del hombre, es una tarea constante que el Derecho debe realizar para comprender acabadamente esa maravillosa armonía.

Servir al hombre es el "que", el destino, la razón de ser del Derecho. Y, se le sirve reconociéndolo tal cual es, otorgándole y garantizándole el disfrute de todos, absolutamente todos, los extremos que le corresponden por su propia dignidad (ampliaremos este concepto al tratar la naturaleza de la cosa).

b) Justicia

El tema de la justicia se desarrolla plenamente en el Capítulo IV, ahora tan sólo lo enunciamos.

La justicia constituye el centro mismo de la idea del Derecho. Es la esencia creadora y directora de cualquier orden jurídico. Desde la antigüedad más remota el hombre intenta describirla, poseerla en su totalidad; de acuerdo a los resultados obtenidos hasta la fecha, no dudamos, que se trata de una ardua tarea, sin embargo, trataremos de dar una respuesta a este antiguo interrogante, en el Capítulo IV.

Lo esencial, para esta parte del trabajo, es señalar que la finalidad del Derecho (paz, seguridad, libertad, igualdad) junto con las exigencias morales (dignidad de la persona del hombre y la justicia) indican no sólo los fines de este orden, sino también, y en gran medida, las causas que mueven al hombre a la creación de un orden jurídico.

El Derecho no sólo ordena las posesiones de cada uno en paz y garantiza el disfrute seguro de lo que se posee, sino que, además, nos plantea —o intenta— que las posesiones y demás relaciones ordenadas por el Derecho no se conviertan en fuentes de explotación y privilegios que terminen privando al prójimo de los derechos presentes en ellos. Porque la orientación de cualquier orden jurídico —como elemento determinante para ser tal— está dado precisamente, por el respeto a la dignidad de la

¹⁶ PERÓN, J. D., *La Comunidad...*, cit., pág. 36.

persona del hombre, y por la búsqueda permanente e ineludible de la justicia como centro motor y ordenador del Derecho.

VII. VISIÓN DE CONTENIDO

Hemos definido el concepto de Derecho. Entendemos al valor justicia como resumen último de todos los valores a realizarse en el orden jurídico, y en tal condición le hemos atribuido su carácter de sustento basal, motor, organizador y orientador del Derecho.

De lo dicho se desprende que entendemos que una norma jurídica es tal, en la medida en que su contenido esté orientado por la justicia, ordenado a ella. No basta, en este sentido, el cumplimiento de los extremos previstos para la sanción y promulgación de esa norma para concluir, sin más, que estamos en presencia de una norma que integra el orden jurídico.

*"Hoy cuando el Derecho como instrumento esencial de la civilización está más que doblemente amenazado, no podemos permitirnos el lujo de una teoría jurídica positiva. Si consideramos meramente la forma del Derecho no podremos captar la diferencia esencial entre el estado de poder y el estado de derecho. Por ejemplo, en la Alemania de Hitler—prototipo del estado de poder— acaso se publiquen diariamente más leyes que en ningún otro país. Si consideramos al Derecho —como lo hacen los positivistas— meramente como un mandato del Estado, promulgado en forma legal, esta Alemania hitleriana sería un estado de derecho par excellence. Ningún estudio meramente formal del Derecho resolverá el problema de por qué el Derecho se encuentra en los estados contemporáneos totalitarios en una posición harto precaria. Si queremos conservar el Derecho, hemos de considerar su contenido. Habremos de considerar la manera de hacerse la distribución de poderes, de derechos y deberes de los individuos, grupos y gobiernos dentro del sistema social, de manera que garantice el imperio y supremacía del Derecho"*¹⁷.

Por lo que reiteramos, el concepto de visión de contenido implica que para que una norma sea considerada de derecho, no nos basta su sanción y promulgación en forma legal, sino que su contenido, además de su sanción y promulgación legal, debe ser sustentado, orientado, motorizado y organizado por la justicia, en su condición de resumen total de todos los valores a realizar por el Derecho.

¹⁷ BODENHEIMER, E., *Teoría del Derecho*, Fondo de Cultura Económica, México, 1979, págs. 9/10.

VIII. LAS RELACIONES SOCIALES

En este punto vamos a analizar las diversas maneras de convivencia humana. Vamos a describir las distintas formas en que el hombre se relaciona con el resto de los hombres, con los que comparte su propio destino, con los que realiza cada día su cotidiana realidad.

Antes de comenzar, haremos algunas salvedades. Toda clasificación responde primordialmente a una necesidad expositiva, es decir, no es la única forma de plantear el tema, sino que se privilegia una cuestión didáctica. Asimismo, las distintas formas de relacionarse que tiene el hombre, no se dan en la realidad, necesariamente, en estado puro. Para su exposición se toman los elementos típicos que hacen a cada forma particular de relación, pero en la vida cotidiana, éstas se entremezclan de tal manera que requiere un esfuerzo del observador, para definir a qué tipo de relación corresponde la conducta observada.

Seguiremos para este estudio a Coing, que a su vez se sustenta en la sistemática creada por Vierkandt.

El hombre se relaciona con sus semejantes mediante relaciones de comunidad, reconocimiento, poder y lucha. No hay más, las posibles relaciones humanas sólo pueden desarrollarse en alguno, algunos o todos de estos cuatro tipos. Pero insistimos, en la realidad, generalmente, no se dan en estado puro, sino que las distintas formas se entremezclan, se penetran mutuamente.

a) Relación de comunidad

*"La comunidad es la más estricta forma de ligamen social"*¹⁸. El ejemplo clásico de este tipo de relación social es la familia. En esta comunidad, los integrantes se conocen personalmente. Cada uno de los miembros viven al grupo y a los avatares y conflictos de cada uno como propios. El problema que afecte a uno se vive y se siente como el problema de todos sus integrantes.

Al conocimiento personal se suma que generalmente viven juntos, en un mismo ámbito.

Aquí existe una mutua inclinación entre sus miembros, que funden voluntariamente el yo en el nosotros.

¹⁸ COING. H., *Fundamentos...*, cit., pág. 85.

b) Relación de poder

La encontramos en aquellas situaciones en que una persona se halla sujeta a la voluntad de otra, o un grupo tiene dominio sobre otro grupo. Esta relación se basa en el predominio de uno sobre otro.

Son ejemplos de este tipo de relación, una orden religiosa y la organización militar.

En este tipo de relación encontramos que una voluntad se subroga a otra, y los intereses de cada parte son contradictorios.

c) Relación de reconocimiento

En esta relación los hombres se encuentran en igualdad y se reconocen recíprocamente los derechos de cada uno. Cada parte es libre, igual e independiente de la otra, se unen para satisfacer determinadas necesidades, que si bien no son comunes, sólo logran resolverlas mediante la participación del otro (v.gr., en la compraventa, uno quiere vender y el otro quiere comprar, la necesidad no es la misma, en cambio la satisfacción es común, ya que sólo se logra mediante la participación del otro).

El ejemplo típico de esta relación es el contrato. Aquí existe un claro predominio de los intereses y objetivos de cada uno, no hay, por lo tanto, una inclinación común.

d) Relación de lucha

Esta situación se puede plantear en dos terrenos, la lucha violenta y la lucha no violenta. Los ejemplos más comunes: para la primera, una situación bélica y para la segunda, una huelga.

En ambos casos encontramos una absoluta contradicción de los intereses y objetivos de cada parte en conflicto. El odio y el deseo de destrucción gobiernan los ánimos de las personas.

Hasta aquí hemos descripto las formas de convivencia humana que pueden darse. A nuestro estudio corresponde ver cómo actúa el Derecho en cada una de estas formas que tiene el hombre de relacionarse con sus semejantes. Ya que, según lo hemos definido, el Derecho es un orden en las relaciones sociales.

IX. EL DERECHO Y LA RELACIÓN DE COMUNIDAD

Hemos dicho que la comunidad es una relación basada esencialmente en el conocimiento personal, en la unión de sus integrantes. La virtud a

realizar en esta situación es el amor, que determina fundir el yo en el nosotros.

*"Por su esencia misma, el Derecho es tan poco adecuado a la comunidad como a la relación de poder. La comunidad descansa —en su prototipo, la familia— en una estrecha convivencia personal. El orden que se establece en esa convivencia es un orden personal; es un orden que nace del peso relativo de las diversas personalidades que constituyen la comunidad; no es un orden fijo y determinado. El estado de ánimo dominante se compone del respeto recíproco, de inclinación y de amor. Estos factores son los que protegen de los abusos, y no los límites legalmente impuestos; así como también, hacen soportables las desigualdades y oposiciones, y hasta ni siquiera las dejan llegar a nivel de conciencia"*¹⁹.

El Derecho, por su condición de orden abstracto, impersonal, que se formula en base a cuestiones típicas y generales, donde no tienen cabida las individualidades, pretende realizar la virtud de la justicia. Lo que implica reafirmar el yo —reafirmar mis derechos, frente a los derechos del otro—. El cambio, en la relación de comunidad, lo que pretende realizarse es el amor, que todo lo une. La fría virtud de la justicia separa y aísla, en tanto que el amor todo lo funde y lo confunde.

Cuando el Derecho penetra en una relación de comunidad, es una cabal muestra de que esta relación está en decadencia, ya que deben apelar al orden establecido por el Derecho para regular sus relaciones. Significa lisa y llanamente que el amor ya no vive en esa relación.

Obsérvese, por ejemplo, las disposiciones sobre sucesiones, las que determinan que los hijos heredan a sus padres en partes iguales, sin embargo, nada obsta a que los hermanos dispongan algún tipo de mejoras con respecto a alguno, en consideración a la situación patrimonial de ellos. O, antes de la reforma al Código Civil, éste planteaba diferencias con respecto al haber sucesorio, entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Ante una situación concreta, perfectamente podía resolverse en contra de estas disposiciones.

Otro ejemplo que es aún más claro, lo encontramos en la regulación sobre matrimonio, al que entendemos como una plena comunidad de vida. La Ley de Matrimonio Civil en el artículo 50 dispone: "Los esposos están obligados a guardarse fidelidad, sin que la infidelidad del uno autorice al otro a proceder del mismo modo"; y, en el artículo 53: "La mujer está obligada a habitar con el marido donde quiera que éste fije su residencia. Si faltase a esa obligación el marido puede pedir las medidas judiciales nece-

¹⁹ COING, H., *Fundamentos...*, cit., págs. 93, 94 y 95.

sarias". Disposiciones éstas que son un claro ejemplo de absurdo. El matrimonio está fundado en una virtud superior a la justicia misma, que es el amor. Si hay amor no se requiere regulación alguna, y cuando en estas situaciones se requiere del orden jurídico para su regulación, significa que ya no existe una plena comunidad de vida y, por lo tanto, tampoco existe el matrimonio.

El instituto de la patria potestad también resulta claro en este aspecto, ya que no se requería de la norma jurídica para que los hombres entendieran y asumieran sus obligaciones con respecto a sus hijos; si en esta relación interviene el Derecho, ya sea por el abandono, o el exceso, resulta claro que no existe el amor filial, el que naturalmente se da. El Derecho no puede crear el amor inexistente. Tan sólo, ante su ausencia, regula la cuestión como si fueran extraños entre sí.

De lo dicho, concluimos que el Derecho es ajeno a la relación de comunidad, y sólo interviene en aquellas ocasiones en que la comunidad ha decaído, a tal punto, que ya no existe como tal.

X. EL DERECHO Y LA RELACIÓN DE PODER

Este tema lo desarrollaremos acabadamente en el Capítulo III, ahora sólo diremos que entre el Derecho y el poder se comparten ciertas características similares, tanto en su aplicación como en su desarrollo histórico, que llevaron a muchos autores a confundir ambos órdenes.

*"La problemática de las relaciones de poder desde el punto de vista de la formación del Derecho se encuentra además en el horizonte determinado por otras circunstancias. La primera es que el poder se opone a toda limitación; el poder tiene una tendencia hacia una expansión desmesurada. Goethe lo ha expresado en los célebres versos de Fausto: Estos pocos árboles que no son míos / me arruinan la posesión del mundo"*²⁰.

El Derecho tiende naturalmente a limitar la acción del poder, lo que implica que se encuentran en una situación irreductible. El poder tiende a crecer sin límites, y el Derecho plantea permanentemente limitar el poder.

En otro orden de ideas, el Derecho tiene una profunda vocación a la igualdad, pretende de manera ineludible lograr el mayor grado de igualdad entre las partes que se relacionan. Por el contrario, el poder plantea una distinta valoración entre el titular del poder y aquellos que están sometidos a él.

²⁰ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 89.

Como dijimos, el poder y el Derecho se encuentran en una situación irreductible, en un enfrentamiento permanente. Si nos hallamos frente a una relación de poder pura, el Derecho carece de significación en ella, por lo que el mismo es inexistente. Por el contrario, cuando el poder deja de ser ilimitado y accede a ser regulado por el orden jurídico pierde su omnipotencia y el Derecho, en tal circunstancia, puede convivir con el orden del poder.

De lo dicho podemos concluir que la función del Derecho frente al poder es limitarlo. La coexistencia de ambos órdenes está signada por este principio de enfrentamiento permanente: El poder tiende a expandirse; el Derecho tiende a limitarlo.

Los instrumentos que utiliza el orden jurídico para limitar el poder son las normas jurídicas (v.gr., Constitución, Ley de Contrato de Trabajo, etc.).

XI. EL DERECHO Y LA RELACIÓN DE LUCHA

En la relación de lucha violenta no hay puntos en común con el Derecho, el orden jurídico tan sólo puede intentar establecer algunas reglas de juego (v.gr., tratamiento de prisioneros de guerra).

*"La relación de lucha se encuentra en clara contradicción con la esencia del Derecho, puesto que se orienta al daño y hasta al aniquilamiento del contrario. Esto es incompatible con la tendencia pacificadora del Derecho. La lucha violenta no es accesible al Derecho más que en la primitiva y limitada forma de éste en la cual no es más que un conjunto de reglas de juego... Pero también con medios pacíficos puede llevarse adelante una lucha: piénsese en la lucha política propia de los estados democráticos o en las modernas luchas laborales. La competencia en una economía de mercado es también un ejemplo de lucha pacífica. En todos estos casos se satisface la exigencia de paz del Derecho"*²¹.

La relación de lucha pacífica que es accesible al orden jurídico, permite resolver una serie de tensiones existentes en toda sociedad. Imaginemos la sucesión de los gobiernos, sin alguna especie de sistema electoral —lo que resulta contradictorio con nuestras convicciones—, por lo que corresponde regular todas las implicancias que esto conlleva. La campaña previa; el acto electoral, carga en sí una enorme cantidad de energía anímica, una enorme potencialidad dispuesta a la lucha, la que debe ser regulada y encauzada por el orden jurídico. O, el funcionamiento de las pa-

²¹ COING, H., *Fundamentos...*, cit., págs. 98/99.

ritarias, donde se encuentran intereses en contradicción y mediante el sistema creado por el Derecho deben dirimir estas diferencias de acuerdo a determinadas pautas, previamente establecidas.

En resumen, la lucha violenta se encuentra en contradicción con el Derecho, en cambio, la lucha no violenta, cuando es regulada por el orden jurídico, permite la resolución de los conflictos subyacentes en la sociedad.

XII. EL DERECHO Y LA RELACIÓN DE RECONOCIMIENTO

La relación de reconocimiento es la que se adapta plenamente al desarrollo del Derecho. Cuando los hombres se encuentran libres, iguales e independientes entre sí, el Derecho gobierna sus relaciones.

La fría virtud de la justicia, que todo lo separa y aísla, sólo puede realizarse en aquellas situaciones donde los hombres privilegian la igualdad y la independencia entre sí. Por ello, la relación de reconocimiento es, precisamente, el ámbito donde se desarrolla el Derecho. Dijimos que el ejemplo típico de esta relación es el contrato. Las partes se encuentran en tal situación libres, iguales e independientes entre sí, cada uno reconoce y respeta los derechos presentes en el otro. Es allí donde la justicia puede gobernar plenamente los actos de las personas.

Entonces, la virtud a realizar en esta relación es la justicia, que separa y aísla; reafirma el yo, los derechos de cada persona, frente a los derechos de otra. Es acá donde la justicia puede dar a cada uno lo que le corresponde.

XIII. EL DERECHO Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Muchos autores pretenden encontrar en el Derecho la expresión del poder consolidado en determinada sociedad. Pareciera que el Derecho es la cristalización de una conquista. Sin embargo, el Derecho es un instrumento esencial del hombre en el tránsito infatigable de su evolución hacia formas de convivencia más justas.

No negamos cierta afinidad histórica entre el poder establecido y el Derecho (gráficamente diríamos que primero fue la espada y luego el Derecho, primero el hombre con poder alambró y luego fue el Derecho de propiedad). Ocurre, que si bien podemos observar en algún momento histórico la afinidad enunciada, no por ello debemos absolutizar esta observación parcial, porque en realidad el Derecho y el poder se encuentran en una situación de contradicción total y absoluta, su lucha es constante y permanente. Pueden en determinado estadio de la evolución desarrollarse

juntos, pero luego cada uno sigue su camino, y el Derecho asume su propio destino. El orden jurídico tiene una razón de ser propia, la que no comparte con ninguna estructura de poder, ésta es: la ordenación de la razón a la justicia; por eso, el devenir común que en algún momento pueden tener ambos órdenes, no perdura por mucho tiempo.

Hemos dicho que lo único que permanece constante en el devenir histórico de la humanidad es su propia evolución. Y que esta evolución tiene un motor, que encontramos en la búsqueda constante de formas de convivencia más justas, en la reafirmación de la dignidad con que cada hombre fue forjado desde todos los tiempos.

Esta evolución, obra de la naturaleza, va a golpear las estructuras sociales, económicas y políticas de la sociedad; cuando la evolución supera a estas estructuras se produce, con mayor o menor esfuerzo, con mayor o menor violencia, un cambio en las mismas (lo que denominamos revolución) y, es allí donde el Derecho viene a consolidar un nuevo estadio en la evolución del hombre.

Primero vienen los hechos y los procesos sociales, luego el Derecho. Por esto, el Derecho aporta y se nos revela como un instrumento esencial en la transformación social, a partir del destino mismo del hombre: buscar incansablemente formas de convivir con sus semejantes a cada paso más impregnadas del valor justicia.

CAPÍTULO III

EL ORDEN DEL DERECHO Y EL ORDEN DEL PODER

Hemos visto en el capítulo anterior la relación de poder y la definíamos como la situación en que una persona o grupo de personas se encuentran sujetos a la voluntad de otra persona o grupo de personas.

Históricamente el orden del Derecho y el orden del poder se han desarrollado juntos. Pareciera que primero se concentró determinado poder y, luego, para consolidar la situación de privilegio que la concentración de poder otorgaba, se crea el derecho, a fin de cristalizar en sus fórmulas el privilegio logrado.

No vamos a negar esta afinidad histórica, que en muchos casos permite afirmar que el Derecho se desarrolló a la sombra del poder. Pero es un error absolutizar esa penetración parcial en el ser del Derecho, ya que ésta no fue ni es la única forma de desarrollo del orden jurídico. Hay miles de ejemplos de ambos casos en la historia. En algunos, el Derecho se consolida a través del poder establecido, en otros, es la orientación de la justicia, motor de la evolución, lo que determina la modificación del Derecho vigente y la instauración del nuevo, con una mayor penetración de lo justo en nuestras relaciones sociales.

De cualquier manera, prescindiendo de esta discusión sobre los primeros tiempos del Derecho, podemos afirmar que el orden del poder y el orden del Derecho se encuentran en una posición de contradicción irreductible.

*"Como resumen puede decirse que, por su esencia, la relación de poder se encuentra en cierta contradicción con el orden jurídico. Cuando la relación de poder se presenta en estado puro, el Derecho tiene que sucumbir. Sólo en formas atenuadas es esta estructura accesible al Derecho. Pero entonces pierde su plenitud y se somete a la limitación jurídica"*¹.

¹ COING, H., *Fundamentos de Filosofía del Derecho*, cit., pág. 91.

Desde el punto de vista sociológico, el poder indica la capacidad o potencia de hacer o no hacer, de realizar su propia voluntad, más allá de la voluntad de los otros individuos, y aun en contra de la voluntad de ellos.

*"Muchos filósofos y sociólogos se han dado cuenta de la tremenda importancia del concepto del poder para el estudio de la vida social humana. Hobbes y Spinoza basaron sus sistemas filosóficos en el supuesto de que todo ser vivo se ve impulsado por un instinto natural a extender su poder lo más lejos que es capaz. La vida es una búsqueda de poder, exclama Emerson. Friedrich Nietzsche consideraba la voluntad de poder como la fuerza motivadora básica de la naturaleza y de la sociedad humana. Todas las cosas —decía— son cuanto dinámicos que están en relación de tensión con otros cuanto dinámicos. El sociólogo norteamericano Lester F. Ward describía la ley de la naturaleza como el derecho de la fuerza"*².

Montesquieu describe el problema de la siguiente manera: *"La democracia y la aristocracia no son estados libres por su naturaleza. La libertad política no se encuentra más que en los estados moderados; ahora bien, no siempre aparece en ellos, sino sólo cuando no se abusa del poder. Pero es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentre límites. ¡Quién lo diría! La misma virtud necesita límites.*

*"Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder. Una constitución puede ser tal que nadie esté obligado a hacer las cosas no preceptuadas por la ley, y a no hacer las permitidas"*³.

Algunos autores confunden el orden del Derecho y el orden del poder, fundamentalmente, a partir de dos cuestiones: *"Un derecho sin poder pareciera ser, para muchos, una expresión carente de significado.*

*"El derecho necesitaría de un poder para realizarse efectivamente. El Derecho se perfecciona a través del poder"*⁴.

Siguiendo el razonamiento del autor citado, enunciamos los elementos que provocan tal confusión, e intentaremos establecer las diferencias sustanciales que aíslan al poder del Derecho.

Estos elementos son tres: orden, paz y seguridad.

² BODENHEIMER, E., *Teoría del Derecho*, cit., pág. 16.

³ MONTESQUIEU, *El Espíritu de las Leyes*, cit., págs. 142/143.

⁴ NEGRI, H., *El Derecho como Orden de Respeto*, El Coloquio, Buenos Aires, 1986, pág. 29.

I. ORDEN DEL DERECHO Y ORDEN DEL PODER

Tanto el derecho como el poder se realizan en un orden, es decir, establecen las posiciones relativas de cada uno de los miembros que ese orden abarca.

"En rigor todo tipo de relación social se despliega internamente en un orden.

"Existen así un orden del amor, un orden de la violencia, un orden del poder y un orden del reconocimiento que es, propiamente, el orden del Derecho.

"El orden del amor, por ejemplo, es un orden altamente inestable. También —aunque por diversos motivos— el orden de la violencia.

"Las posiciones de los distintos individuos fluyen y se modifican incesantemente.

"El poder y el Derecho proporcionan en cambio un orden estabilizado (o, por lo menos, fácilmente estabilizable).

*"Las delimitaciones recíprocas, una vez consolidadas, tienden a conservarse"*⁵.

La inestabilidad que encontramos en el orden del amor (relación de comunidad) y de la violencia, nos lleva a considerar semejantes el orden del Derecho y el del poder. Pero esta semejanza, sólo llega a eso, es decir ambos órdenes tienden a estabilizar las posiciones de los miembros que lo integran. La diferencia sustancial entre ambos surge cuando penetramos en el orden mismo, y analizamos cuáles son y el contenido de cada una de las posiciones que se estabilizan.

*"Porque mientras que el orden del Derecho es el orden de la igualdad, la autonomía y el respeto recíproco, el orden del poder es el orden de la coacción, de la represión y de la pena"*⁶.

O, dicho en otros términos, el orden del Derecho tiende a estabilizar relaciones sociales gobernadas por la igualdad, la libertad, el respeto a la dignidad moral del hombre y la justicia, mientras que el orden del poder pretende estabilizar relaciones, donde lo que se impone es una profunda desigualdad entre el titular del poder y aquel que se encuentra sujeto a ese poder, donde la libertad es inexistente, ya que la adhesión del individuo se logra a partir de la coacción, la represión y la pena, y el respeto al hombre no es más que una declamación, ante la desigualdad y la falta de libertad; por último, el orden del poder no pretende dar a cada quien lo que le corresponde, sino lo que le conviene al titular del poder.

⁵ NEGRI, H., *El Derecho...*, cit., págs. 34/35.

⁶ NEGRI, H., *El Derecho...*, cit., pág. 36.

II. LA PAZ DEL DERECHO Y LA PAZ DEL PODER

El segundo punto de confusión lo encontramos en la búsqueda de la paz. Tanto el derecho como el poder pretenden instaurar en sus ámbitos respectivos la paz. Requieren para su propio desarrollo y sostenimiento de la paz, sin ella ni el poder ni el Derecho pueden subsistir.

Obsérvese que el poder no podría imponerse en una situación donde existe la violencia, ya que la presencia de ésta indica que sus pautas no logran consolidarse en esa situación concreta. Lo mismo ocurre con el Derecho, en una situación de violencia, el orden jurídico tiene muy poco margen para su desarrollo.

"El poder suministra una paz a la que podríamos llamar puramente externa, aparente.

"Bajo esa paz se suelen encubrir tensiones muy grandes, neurosis y conflictos sociales que hacen eclosión apenas el poder disminuye sus métodos constrictivos de vigilancia" ⁷.

III. LA SEGURIDAD DEL DERECHO Y LA SEGURIDAD DEL PODER

Hemos dicho que la paz como la seguridad son finalidades del orden jurídico. La seguridad corresponde a la misma naturaleza del hombre, que pretende asegurar su vida más allá de los avatares y eventualidades que el futuro pueda depararle.

Tanto el poder como el Derecho requieren para su propio desarrollo la seguridad, pero aquí, como en el tema de la paz, la similitud de ambos órdenes sólo es externa y aparente. *"Las diferencias entre la seguridad del Derecho y la falsa seguridad del poder son dos fundamentales. Por un lado, el medio como se realizan los procedimientos, en un caso respetuosos, en otro caso constrictivos. Por otro, el hecho de que la seguridad del poder se circunscribe a la seguridad relativa entre los dominados pero deja subsistente íntegramente el problema de la falta de seguridad frente a quien ejercita el poder.*

"En este último sentido, la única seguridad que el poder proporciona a quienes están sujetos a él respecto de quienes lo detentan es la de estar sometido a voluntades arbitrarias" ⁸.

Para concluir con este tema reiteramos que el Derecho y el poder se encuentran en una constante contradicción. En una situación donde existe un poder absoluto, el Derecho no puede subsistir. Sólo en aquellas situa-

⁷ NEGRI, H., *El Derecho...*, cit., pág. 37.

⁸ NEGRI, H., *El Derecho...*, cit., pág. 38.

ciones en que el poder pierde su expresión totalitaria y se aviene a las limitaciones que le impone el orden jurídico pueden coexistir.

"En la vida histórico-política estas limitaciones del poder no han resultado posibles más que cuando el poder mismo se consideró como una entidad portada por todos los sujetos de derecho y ejercida en su nombre. Tal fue el caso de la polis griega; lo mismo puede decirse del poder de los magistrados en la Roma Republicana o del estado de derecho moderno. Es el pueblo en todas estas formaciones el que otorga el poder, y por eso el poder está limitado ante el pueblo por el Derecho" ⁹.

IV. FORMAS EXTREMAS DE PODER

En la vida social se han desarrollado dos tipos característicos que representan a su vez dos formas extremas de plantearse el poder en términos absolutos y, como consecuencia, inasibles para el orden jurídico. Éstos son la anarquía y el despotismo.

a) Anarquía

En la anarquía, cada miembro del grupo tiene en sí la totalidad del poder, no hay límite alguno al ejercicio pleno de la voluntad de cada quien. Todos los hombres pueden hacer o dejar de hacer según sus propios deseos sin estar vinculados a ninguna norma que determine previamente la conducta frente a situaciones concretas. Es decir, la absoluta totalidad del poder se encuentra en cabeza de cada individuo.

"Donde impera la anarquía no hay reglas coactivas que todo individuo esté obligado a reconocer y obedecer. Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. No hay Estado o gobierno que imponga límites al ejercicio arbitrario de ese poder" ¹⁰.

Esta situación social, en los términos descriptos, no ha tenido cristalización alguna en la historia del hombre, sólo existe como teoría sustentada en la convicción de que el hombre es esencialmente bueno y que el Estado y el Derecho lo corrompen, por lo que es de prever que eliminando las causas (el Derecho y el Estado) desaparecerán también las consecuencias. En definitiva, el planteo es que con la eliminación del Estado y todas sus instituciones el hombre retornará a sus orígenes de bondad natural.

⁹ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 92.

¹⁰ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., págs. 18/19.

Como hemos dicho, esta teoría no dejó de ser jamás un planteo hipotético. Sin embargo, en el mismo terreno de la teoría puede establecerse que el estado de anarquía es contrario a los aspectos esenciales del hombre. Por ejemplo, la seguridad. El hombre necesita lograr un mínimo de seguridad y previsibilidad tanto de sus actos como los de sus semejantes, quiere garantizar cierto tipo de convivencia pacífica y segura, más allá de lo que suceda a cada instante, y del humor que cada uno tenga en cada momento. La anarquía impide realizar este concepto de seguridad, por lo que ocurrirá como consecuencia necesaria la violencia en las relaciones sociales. La lucha entre los hombres y el resultado previsible, el triunfo de unos sobre otros, provocará la otra forma extrema del poder: el despotismo.

b) Despotismo

En el otro extremo de la anarquía encontramos al despotismo. *"El despotismo es una forma de gobierno en la que un hombre goza de un poder ilimitado sobre los súbditos a los que rige. Puede manifestarse en dos formas. En primer término, puede significar el régimen puramente arbitrario y caprichoso de un hombre que trata de dominar a otros para satisfacer un ansia personal de poder. En segundo lugar, puede aparecer en forma de una idea o propósito impersonal que el déspota intenta—o finge querer—realizar. La segunda forma de despotismo tiene más éxito y es a la vez más peligrosa"*¹¹.

En esta situación, todos los integrantes del grupo se encuentran a merced de la arbitrariedad y capricho de aquel que detenta el poder. La conducta de éste no está atada a ninguna regla general, a la que deba responder, por lo que actuará conforme a su humor y a las simpatías o antipatías que le despierten eventualmente las personas y situaciones sujetas a él. Nada escapa a esta regla, el humor del déspota será la norma a la que tienen que ajustar las conductas todos aquellos sujetos al poder ilimitado.

"Este es el rasgo característico del poder arbitrario: su detentador no se considera obligado a tratar de igual modo las situaciones iguales. No reconoce ninguna norma con arreglo a la cual ejerce su poder. Castiga si se siente con humor para hacerlo así; indulta cuando le parece. Actúa movido por caprichos e impulsos irracionales y no por motivos objetivos o consideraciones de razón... En la cultura moderna el despotismo no ha desaparecido, pero se disfraza generalmente de una forma más impersonal. En un estado totalitario moderno, el déspota trata de relacionar

¹¹ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., pág. 21.

*su poder con alguna aspiración o ideal más elevado, al que afirma servir... Un gobernante autocrático como Hitler se considera a sí mismo como mero ejecutor de la voluntad colectiva del pueblo alemán"*¹².

El Derecho en esta situación no desaparece, sino que se lo descarna, se le quita su contenido ordenado a la justicia y se transforma, por tal motivo, en una mera formalidad. Las leyes se dictan y se modifican de acuerdo a las formas y procedimientos establecidos, sin detenerse y ni siquiera considerar el contenido de la norma dictada. Estos actos, en última instancia, sólo persiguen, de manera tanto consciente como inconsciente, acrecentar hasta donde le fuera posible el poder del déspota. Frente a este fenómeno descrito, el Derecho se convierte en una mera formalidad. Las teorías del positivismo jurídico no tienen respuesta para esta enorme claudicación.

Hemos afirmado que en estas situaciones, el Derecho no desaparece, pero se transforma de tal manera que ya no es posible identificarlo como tal. En el orden del poder, cuando éste no se aviene a ser regulado y limitado por el orden jurídico, el Derecho lentamente se transforma, hasta el punto culminante de colocarse al exclusivo servicio del poder. Lo que nos permite afirmar que nos encontramos frente a la formalidad que reviste el Derecho, pero jamás ante un verdadero orden jurídico (ver Cap. II, Visión de contenido).

"Otro hecho que convierte los Estados totalitarios modernos en estructuras de poder arbitrario es la posibilidad ilimitada de modificar las leyes. Este rasgo característico del totalitarismo moderno es más visible en Alemania que en ningún otro país. Desde 1933 la función legislativa ha sido delegada totalmente al gabinete alemán y a su jefe Adolf Hitler. El gobierno modifica la ley con gran frecuencia e incluso con fuerza retroactiva. No hay salvaguardias constitucionales que establezcan limitaciones a la legislación arbitraria. En el campo administrativo el poder del gobierno o de sus funcionarios de policía de internar a cualquier ciudadano en un campo de concentración sin expresar ningún motivo, puede ejercerse de un modo puramente arbitrario y caprichoso. Incluso personas a las que el tribunal ha absuelto de la imputación de un delito político, pueden ser internadas en un campo de concentración si el führer desapruueba la decisión. Ejemplo destacadísimo de tal ejercicio arbitrario del poder fue la famosa 'purga' del 30 de junio de 1934 en la que los líderes nazis opositoristas fueron ejecutados sin proceso. El acto que se reconoce no estaba justificado por el derecho escrito, fue legalizado posteriormente por

¹² BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., pág. 22.

medio de una ley de efecto retroactivo, firmada por el autor de las ejecuciones y dos miembros de su gabinete"¹³.

Sin necesidad de irnos tan lejos tanto en el tiempo como geográficamente, en nuestro país tenemos innumerables muestras de situaciones similares a la descrita en el párrafo anterior. Como ejemplo, transcribimos algunos artículos del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, de fecha 24 de marzo de 1976 y publicado en el *Boletín Oficial* el día 31 de marzo de 1976: "Considerando que es necesario establecer las normas fundamentales a que se ajustará el gobierno de la Nación en cuanto a la estructura de los poderes del estado... La Junta Militar en ejercicio del poder constituyente, estatuye:

"Artículo 1º.— La junta militar integrada por los comandantes generales... órgano supremo de la Nación, velará por el normal funcionamiento de los demás poderes del Estado... Y designará al ciudadano, que con el título de presidente de la Nación Argentina, desempeñará el Poder Ejecutivo de la Nación...

"Artículo 2º.— La junta militar podrá, cuando por razones de Estado lo considere conveniente, remover al ciudadano que se desempeña como presidente de la Nación, designando a su reemplazante mediante un procedimiento a determinar.

"También, inicialmente removerá y designará a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al procurador general de la Nación y al fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

"Ejercerá, asimismo, las facultades de los incisos 15, 17, 18 y 19 del artículo 86 de la Constitución Nacional que otorga al Poder Ejecutivo nacional, así como también las que los incisos 21, 22, 23, 24, 25 y 36 del artículo 67 atribuyen al Congreso...

"Artículo 5º.— Las facultades legislativas que la Constitución Nacional otorga al Congreso incluidas las que son privativas de cada una de las Cámaras, serán ejercidas por el presidente de la Nación..."

Los párrafos transcriptos del estatuto dictado el 24 de marzo de 1976, no requieren un pormenorizado análisis, ya que de su simple lectura surgen los elementos que permiten aseverar que este estatuto no forma parte alguna de lo que hemos denominado orden del derecho, sino que es la expresión de un poder despótico, que nada tiene en común con el orden jurídico, tan sólo comparten la forma con que se expresan y, además, utilizan parecidos sistemas para la instauración de una nueva norma jurídica

¹³ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., págs. 23/24.

(v.gr., su publicación en el *Boletín Oficial*). Pese a ello, no podemos concluir que la norma transcrita es parte integrante del orden del Derecho. Ya que, como se observa de su simple lectura, es una posición del poder, puesta por un grupo, que por la fuerza se apoderó de las estructuras del Estado.

V. TIPO IDEAL DE DERECHO

Hemos planteado estas dos formas extremas de manifestarse las relaciones de poder en la sociedad humana. El Derecho pretende de manera ineludible limitar el poder. Busca lograr que este deponga su actitud de expansión desmesurada. En ambas situaciones descriptas el poder se ejerce sin ningún tipo de limitación, por lo tanto, estas formas son inaccesibles para el orden jurídico.

Siguiendo a Bodenheimer, planteamos que: "*Por su propia naturaleza el Derecho es un término medio entre la anarquía y el despotismo. Trata de crear y mantener un equilibrio entre estas dos formas extremas de la vida social*"¹⁴.

A fin de evitar los extremos en que el poder puede enseñorearse en la sociedad, el Derecho limita al máximo el ámbito de poder de los particulares y del Estado. De manera tal que la anarquía (todo el poder en cabeza de cada uno de los individuos) y el despotismo (todo el poder en cabeza de uno o de unos pocos) no tienen posibilidades de desarrollarse en aquellas comunidades regidas por el Derecho.

De lo dicho se deduce que es función primordial del derecho limitar el ejercicio arbitrario, abusivo e ilimitado del poder, tanto por parte de los particulares como por parte del Estado, sus órganos y sus funcionarios.

Hemos dicho que el Derecho limita al poder. Esta afirmación requiere una mayor precisión, ya que no toda limitación al poder viene del Derecho y esto puede traer confusiones. Un poder también puede ser limitado por otro poder (v.gr., en un gobierno despótico, el déspota puede encontrar grandes limitaciones en su accionar impuestas por grupos económicos, o por una oposición fuerte que restrinja el ámbito de decisión arbitraria del gobierno).

Como vimos en este ejemplo, un gobierno autocrático puede encontrarse limitado en su accionar, pero esta limitación surge de otros grupos de poder.

¹⁴ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., pág. 26.

Para que la limitación al poder surja del orden jurídico, ésta se debe dar a partir de la adecuación de las conductas a determinadas reglas generales, puestas por el Derecho.

Así vemos, por ejemplo, que la Constitución de la Nación limita el poder del Estado mediante la división de poderes. También, desde otro ángulo, se limita el poder de los empresarios, con respecto a los trabajadores mediante la Ley de Contrato de Trabajo.

*"Para conocer y comprender un fenómeno es necesario contemplarlo en su forma más pura y desarrollada... Sólo describiendo un sistema jurídico desarrollado en que se hayan realizado todos los elementos típicos y esenciales del Derecho en su forma pura puede entenderse el verdadero significado del término Derecho"*¹⁵.

Vamos a describir el tipo ideal de Derecho; sabemos que —como tipo ideal— jamás se realiza plena y absolutamente en la realidad, tan sólo pretende ser un patrón donde poder medir y comparar con cierta seguridad. Sólo a partir de un ulterior análisis y comparación entre el tipo ideal y la realidad concreta podremos afirmar que efectivamente nos encontramos frente a normas jurídicas, o por el contrario, estamos frente a meras posiciones de poder, tanto de grupos particulares como de aquellos que se han encaramado en las estructuras del Estado.

*"Como hemos visto, el Derecho es un término medio entre la anarquía y el despotismo. El peligro de la anarquía consiste en la posibilidad de un abuso arbitrario de poder por parte de todos y cada uno de los individuos. El riesgo del despotismo estriba en la posibilidad del abuso arbitrario de poder por parte de un hombre. El tipo ideal de Derecho evitará a la vez los dos peligros. El Derecho en su forma pura y perfecta se realizará en aquel orden social en que esté reducida al mínimo la posibilidad de abuso de poder tanto por parte de los particulares como por parte del gobierno"*¹⁶.

Al analizar la finalidad del orden jurídico (Cap. II) vimos, entre otras, la igualdad, y dijimos que el Derecho importa una profunda vocación a la igualdad. Que este orden en las relaciones sociales se da únicamente cuando, a su vez, también se da una relación de personas libres, iguales e independientes entre sí. Por lo que una acumulación privilegiada de poder para un grupo, sector o persona, provoca una desigualdad que afecta a todo el orden jurídico. Implica esto que el reparto de obligaciones y derechos que realiza el orden jurídico debe estar sustentado en cuestio-

¹⁵ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., pág. 31.

¹⁶ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., pág. 32.

nes objetivas, que preserve la igualdad de todos sus integrantes de acuerdo a su ubicación específica dentro del orden que lo abarca. El sustento brindado por cuestiones objetivas implica observar plenamente lo que surge de la naturaleza de la cosa sujeta a regulación (sobre este tema volveremos en el Cap. VIII).

*"El Derecho en su forma más pura no puede prevalecer si la esfera de poder permitida a los particulares o a los grupos privados es demasiado amplia. Es igualmente cierto el caso inverso. El Derecho no puede florecer si los grados de poder atribuidos a los individuos o grupos es demasiado estrecho. En tal caso tiene que existir necesariamente un poder público abrumadoramente fuerte, que restringirá en tal medida la libertad individual, impidiendo con ello el imperio del Derecho. El Derecho exige el reconocimiento de una esfera bien definida de poder, dentro de la cual el individuo esté libre de las invasiones arbitrarias del gobierno... El Derecho en su forma pura presupone, pues, una cierta generalidad e igualdad en la asignación de derechos. Cuanto más se aleja el Derecho del poder y más se aproxima a su forma ideal, mayor importancia se ve obligado a atribuir a la realización de la igualdad"*¹⁷.

La igualdad planteada significa alejar, restringir toda posibilidad de concentración del poder. En una sociedad donde se plantea una igualdad de posibilidades sin detenerse en la situación particular de cada uno, generará necesariamente desigualdades materiales que dará lugar a cierto tipo particular de dominación, la económica, resultado de la acumulación de riquezas en unas pocas manos en detrimento de las mayorías, las que se encontrarán sujetas al poder de otros, poder que se sustenta en la posesión de bienes.

*"Un orden social basado en una oportunidad igual y sin obstáculos para todos acabará por ser, finalmente, un orden basado en una igual oportunidad para pocos; es decir, que a menos que se produzca una redistribución de poder, una época de laissez-faire desembocará en una época de monopolio y privilegio. Por esta razón el Derecho en su forma pura favorece el establecimiento de una igualdad de condición"*¹⁸.

Por otro lado, el gobierno debe poseer en sí el poder suficiente para enfrentar con éxito a la anarquía, superando los intereses individuales, a fin de conducir a la sociedad hacia la consecución del bienestar general.

¹⁷ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., págs. 35/41.

¹⁸ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., págs. 41/42.

Pero este poder debe estar limitado a su vez para evitar que se transforme en un estado despótico, lo que se logra cuando el accionar del gobierno se encuentra entre límites perfectamente establecidos y definidos.

*"Poder y Derecho en sus formas puras son polos opuestos. El uno representa la idea de una potencia arbitraria, no restringida por ninguna regla de conducta. El otro polo representa la idea de un sistema social en que el poder está limitado por un máximo de frenos y contrapesos eficaces"*¹⁹

VI. ESTADO, SOBERANÍA Y PODER

En este punto vamos a analizar el tema de la soberanía del Estado en el marco del problema del poder. No pretendemos encarar el estudio de un espacio que corresponde a la ciencia política, tan sólo tomaremos algunos conceptos de ella para volver inmediatamente al tema que nos ocupa que es el poder y el Derecho.

M. Prelot define al Estado como: *"El Estado es una forma calificada, perfeccionada, eminente de la vida colectiva; se origina en una creación de la voluntad y la razón humanas que aplica sus esfuerzos y reflexiones al problema de la organización política, y logra asegurar su continuidad. En consecuencia, como lo ha explicado muy bien Georges Buerdeau, sólo hay Estado donde la autoridad ha sido institucionalizada, o sea, allí donde hay una diferenciación de funciones públicas que las separa de las otras formas de vida social, que las instituye, y órganos propios que las centralizan para hacer surgir la unidad del Estado soberano"*²⁰. Y, antes había afirmado: *"El Estado, el poder y la sociedad son indisolubles"*²¹.

A nosotros, de esta muy compleja cuestión sólo nos interesa cómo debe actuar el derecho, para limitar el poder del Estado, es decir, su soberanía; para evitar el abuso y, en consecuencia, que se convierta en un Estado despótico.

Sobre esta cuestión se han desarrollado tres teorías que determinan tres posturas distintas.

a) El Estado se encuentra en una situación de superioridad con respecto al Derecho.

b) El Derecho tiene preeminencia sobre el poder del Estado.

¹⁹ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., pág. 43.

²⁰ PRELOT, M., *La Ciencia Política*, Eudeba, Buenos Aires, 1972, pág. 83.

²¹ PRELOT, M., *La Ciencia...*, cit., pág. 83.

c) El Derecho y el Estado son exactamente la misma cosa.

La primera de ellas —el Estado por sobre el Derecho— fue desarrollada por Austin, Hobbes, Bentham. Esta concepción se basa en el principio *princeps legibus solutus est* (el gobernante supremo está libre de las restricciones de la ley).

Esta teoría fue desarrollada de manera coherente y rigurosa por Austin. En su opinión, el Derecho no era otra cosa sino el mandato del soberano. En toda sociedad, decía Austin: *"Hay alguna persona individual o grupo de personas que recibe habitualmente la obediencia de los miembros de la sociedad. Esta persona —o combinación de personas— siempre que no obedezca, a su vez, habitualmente a otro superior, es el soberano de esa sociedad. La posición de los otros miembros de la sociedad respecto de ese superior es de sujeción. El soberano tiene el poder de obligar a los otros miembros de la comunidad a hacer exactamente lo que le plazca. Es el creador único del Derecho"*²².

Hobbes, otro teórico del absolutismo, nos plantea: *"El resultado de este pacto es la renuncia al derecho natural sobre todas las cosas que cada uno tiene en favor de un tercero, el soberano, que, por lo demás, no es parte contratante ni queda, por tanto, ligado por obligación alguna hacia los súbditos. El Estado que así nace —ya tenga forma monárquica, aristocrática o democrática— goza de un poder absoluto sobre los súbditos: es el Estado Leviathan, en el cual el principio autoritario alcanza su máxima expresión. Sólo de esta manera —piensa Hobbes— podrá cumplir el Estado su fin esencial, que es el mantenimiento de la paz entre los hombres. Si la transmisión de los derechos y de la libertad naturales no fuese absoluta, y en la medida en que no lo fuesen, continuaría el estado de guerra (entre las atribuciones de que queda investido el soberano figura, naturalmente, la de hacer y derogar la ley. Hobbes no quiere saber nada de una división de poderes, que debilitaría la soberanía. Esta es absoluta e indivisible)"*²³.

Esta teoría repugna a lo que venimos diciendo sobre la función del Derecho frente al poder, que es limitarlo. Al plantear la inviolabilidad del orden jurídico, como uno de los rasgos del derecho, dijimos que tanto el que pone el Derecho, como el que apela a él, ambos se encuentran sujetos a las mismas reglas generales de conducta. Cuando comparamos el orden del poder con el orden del Derecho, afirmamos que ambos órdenes plantean consolidar la seguridad en sus respectivos ámbitos, pero en el orden

²² BODENHEIMER, B., *Teoría...*, cit., págs. 70/71.

²³ RODRÍGUEZ HUSCAR, *Introducción al Contrato Social de Rousseau*, Orbis, Buenos Aires, 1984, pág. 143.

del poder ésta, es sólo aparente, ya que subsiste la totalidad del poder en manos de un titular que no se encuentra vinculado por la misma norma, lo que permite filtrar cualquier tipo de conductas caprichosas y arbitrarias.

Es precisamente esta teoría la que justifica y da pie a la existencia de estos excesos enunciados. Ya que el Derecho (reglas generales de conducta), vinculan sólo a los súbditos, dejando subsistente la posibilidad de violar el orden establecido al titular del poder, ya que éste no se encuentra atado por norma alguna.

En la posición opuesta, es decir, el Derecho está por sobre el Estado, encontramos a las teorías del iusnaturalismo clásico.

Los filósofos iusnaturalistas consideran que las normas fundamentales de todo orden jurídico tienen como fuente la divinidad, o a la propia naturaleza humana, por lo tanto, su vigencia trasciende todo tipo de fronteras y organizaciones políticas. Lo que implica que las normas jurídicas corresponden al hombre por el solo y simple hecho de ser hombres. Ellas comprenden y obligan a todas las naciones, a todos los tiempos y a todos los hombres.

De lo dicho se infiere que el Estado debe respetar lo que dispone el derecho natural, de lo que se colige una clara dependencia del Estado con respecto al Derecho, ya que su soberanía actúa, dentro de los límites impuestos por ese conjunto de normas inmutables y eternas, que se sustentan en la propia naturaleza del hombre. Cuya violación por parte del Estado transforma a éste en ilegítimo.

*"Según Krable, la idea moderna del Estado reconoce la autoridad impersonal del Derecho como poder gobernante de la vida social humana. No es la voluntad del soberano, sino la convicción jurídica del pueblo la que da fuerza obligatoria al derecho positivo. Ningún Derecho es válido si no es conforme al sentimiento jurídico que prevalece en la comunidad. El sentido jurídico que prevalece en la comunidad es la única fuente de todo derecho. Una ley que continúe figurando en la colección legislativa, a pesar de que haya cambiado el sentido jurídico del pueblo, pierde su fuerza obligatoria"*²⁴

Sin que esta teoría nos aclare en forma satisfactoria el problema en análisis, consideramos que tiene algunas penetraciones esenciales en el tema. No es el poder del Estado (su soberanía) lo que da fuerza vinculatoria al orden jurídico vigente en un tiempo y en un lugar determinado (derecho positivo) sino que, en última instancia, el derecho positivo se en-

²⁴ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., págs. 73/74.

cuentra seguro en la misma medida de las convicciones jurídicas suprapositivas del pueblo de que se trate.

El Derecho no es una posición del poder, sino que es una creación humana en la que se pone de manifiesto un conjunto de valores, captados conforme al estadio de evolución de la sociedad que lo crea.

Por último, la tercera teoría considera que el Derecho y el Estado son exactamente lo mismo, las dos caras de una misma moneda.

Esta teoría fue desarrollada de manera rigurosa por Hans Kelsen. Su obra fue de tal magnitud, y de tanto rigor científico, que en nuestro tiempo se han multiplicado sus seguidores, sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo, comenzaron a escucharse voces contra estas convicciones, que en última instancia implican una intolerable claudicación del Derecho ante el poder.

*"En su opinión —de Kelsen— Derecho y Estado no son meramente dos aspectos o dos lados del mismo fenómeno; son totalmente y sin reservas idénticos. Todo acto del Estado es a su vez acto jurídico. Toda definición del Estado es a la vez una definición del Derecho. No supone la más mínima diferencia que el Estado de que se trate sea autocrático o democrático, que sea Estado de poder o sea Estado de derecho. El poder del Estado es meramente la suma total de normas coactivas válidas en una sociedad dada; lo mismo es el Derecho. Según Kelsen es algo totalmente injustificado hablar de un dualismo entre el Derecho y el Estado"*²⁵

Este planteo implica un escepticismo insoportable, una resignación inconcebible para un jurista.

El destino del Derecho es la interpolación de lo justo en la sociedad humana. El jurista, el abogado, como custodios, como curadores del orden jurídico, tienen el deber y el compromiso de luchar por la consolidación del Derecho (en su cabal comprensión). Plantear que todo Estado es estado de derecho, es una claudicación inaudita.

Los pueblos han soportado —cada uno a su turno— largos períodos de profunda oscuridad, dominados por la injusticia, a partir de la instauración en los órganos del Estado de un poder autocrático. El Derecho no puede resignarse a que se cometan todo tipo de tropelías en su nombre. La responsabilidad de que esto no ocurra corresponde a todo el pueblo y, esencialmente, a los hombres de derecho.

Planteado el problema y las distintas opiniones que hemos expuesto, corresponde definir el concepto de soberanía, que en esencia significa el supuesto de la inexistencia de un poder superior; es supremo, absoluto, sin

²⁵ BODENHEIMER, E., *Teoría...* cit., pág. 75.

control posterior. En toda comunidad política el soberano no está sujeto a autoridad alguna. Por sobre él, Dios o la nada.

Las opiniones de los autores citados no tomaron el problema objetivamente, sino que utilizaron los conceptos de Estado, soberanía y poder, para justificar determinadas teorías políticas.

A esta altura, cabe preguntarse si en nuestros días continúa teniendo vigencia e interés este tema. *"Para los súbditos de los nuevos estados despoticos del siglo XX significa ciertamente algo —se refiere al concepto de soberanía— 'el poder de que goza un gobernante autocrático como Adolf Hitler, es el ejemplo más extremo que cabe imaginar de soberanía al modo de Austin. Es un poder que no está sujeto a freno ni limitación de ninguna especie. No hay reglas jurídicas que no puedan ser cambiadas en cualquier momento por un simple decreto del fñhrer. El poder de éste excede en mucho los límites que Bodino, e incluso Hobbes, deseaban dar a su soberano, porque estos pensadores reconocían ciertas reglas de derecho natural que servían al menos como guía moral al soberano, pero la moderna dictadura fascista no reconoce ninguna guía moral para la autoridad soberana, salvo exigencias de la política de poder'"*²⁶.

Pareciera que la humanidad tiene un retorno cíclico a formas perversas de organización política. El autor citado se refiere a Hitler, que quizás es un ejemplo que en nuestros días parezca superado. Pero en América latina la existencia de gobiernos autocráticos se reiteran periódicamente. No podemos afirmar que este peligro, tanto en América latina en general, como en nuestro país en particular, esté superado.

*"En realidad el problema de la soberanía, como tantos otros problemas de la ciencia del derecho, está estrechamente ligado y conexo con el problema de poder y Derecho. En una comunidad política en la que el poder está dividido entre una serie de órganos sometidos a una serie de complicados sistemas de restricciones legales, será imposible encontrar un superior humano determinado al que estén sujetos los demás miembros de la sociedad. En tal Estado la autoridad impersonal del Derecho tiene rango superior al de algún gobernante o cuerpo gobernante específico"*²⁷.

Sin embargo, el tema de la soberanía en nuestros días aún conserva cierto tipo de importancia, en el sentido de mantenerla circumscripita y sometida al orden jurídico imperante en la sociedad de que se trate, como fenómeno propio de las comunidades políticas.

²⁶ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., pág. 87.

²⁷ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., pág. 89.

*"La vida diaria real de los ciudadanos está gobernada actualmente por códigos profesionales interiores de las fábricas, acuerdos comerciales o reglamentos de los clubes. Pero en caso de que estas fuentes de autoridad entren en conflicto —entre sí o con las leyes promulgadas por el Estado— la última palabra en la materia corresponde al Estado. El Estado es la sede de un último residuo de autoridad. Esta autoridad puede ser circumscripita y limitada por disposiciones de derecho constitucional. Pero el Estado es una autoridad superior a las de las otras organizaciones que haya dentro de las fronteras nacionales"*²⁸.

Todo lo dicho se refiere al concepto de la soberanía dentro del territorio de cada nación. En las relaciones internacionales el concepto de soberanía adquiere otro perfil, delineado por la búsqueda de la igualdad de todas las comunidades nacionales y una constante lucha enfrentando todo tipo de dependencia de los pueblos.

VII. EL ESTADO DE DERECHO. LÍMITES AL PODER

Hemos visto el concepto de soberanía como sede del último residuo de autoridad. Este soberano se encuentra circumscripito y limitado por las disposiciones del orden jurídico.

Estamos muy lejos de ver a la comunidad política, organizada sobre la base de un pacto entre los ciudadanos, pacto del que no es parte el soberano y por tal motivo no se encuentra vinculado al mismo. Por el contrario, esa organización propia y natural del hombre que entendemos es la sociedad, requiere a su vez de una particular forma, para obtener una personalidad independiente de los miembros que la conforman, por tal motivo surge el Estado como acto de creación de la voluntad humana, para otorgar determinada personalidad a la sociedad que naturalmente conforma con otros hombres. Este Estado como fenómeno necesario de la comunidad humana se encuentra vinculado al estadio de evolución de la misma. Por lo tanto, está atado a la búsqueda constante de formas de convivencia más justas, en ese tránsito infatigable hacia la perfección.

El Estado de Derecho es aquel que mediante un complejo sistema de frenos y contrapesos, impuesto por el orden jurídico, limita el poder de cada uno de sus funcionarios y órganos.

Nuestra Constitución establece en su Segunda Parte, las autoridades de la Nación. El Título Primero, Secciones I, II y III, se refiere a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En el Título Segundo trata sobre los go-

²⁸ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., págs. 90/91.

biernos de los Estados provinciales. En los artículos 36 a 110, la Constitución delinea la estructura del Estado nacional y de cada una de las provincias, determinando específicamente el ámbito de competencia de cada órgano. Crea una compleja estructura donde el poder atribuido a cada uno de los órganos, se encuentra en perfecto equilibrio con las atribuciones que la misma Constitución otorga a los otros órganos y a los particulares. De tal manera que ninguno podrá avanzar más allá de la precisa esfera, previamente establecida, que corresponde a la competencia propia. Lo que garantiza el disfrute pleno de los derechos y garantías de cada uno de los individuos integrantes de la comunidad nacional, reconocidos en la Primera Parte de la Constitución.

En última instancia, la supremacía del Estado por sobre todas las organizaciones que puedan existir y coexistir dentro de cada comunidad nacional, se sustenta en que, mientras que cada organización persigue fines y objetivos particulares o de sector, el Estado encuentra su propia legitimación en la promoción del bienestar general.

"Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la comunidad civil son conscientes de su propia incapacidad para realizar una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comunidad más amplia, en la que se conjuguen, día tras día, sus fuerzas en vista de una constante mejora del bien común. Por ello, forman una comunidad política según diversos tipos. La comunidad política nace, pues, de la búsqueda del bien común: en él encuentra su justificación plena y su sentido, y de él saca su legitimidad primitiva y exclusiva... Pero son muchos los hombres que se encuentran en una comunidad política y pueden legítimamente inclinarse hacia soluciones opuestas. Por consiguiente... es indispensable una autoridad que sea capaz de orientar hacia el bien común el conjunto de las energías de los ciudadanos, no ya de una manera mecánica o despótica sino, ante todo, obrando como una fuerza moral que se apoya en la libertad y responsabilidad de cada uno. Es pues, evidente que la comunidad política y la autoridad pública tengan su fundamento en la naturaleza humana... Síguese también que el ejercicio de la autoridad política, sea en el interior de la comunidad o de las instituciones que representan al Estado, debe exteriorizarse, efectivamente, dentro de los límites del orden moral, según las exigencias del bien común, entendido en forma dinámica y según un orden jurídico debidamente establecido... Pero cuando la autoridad, extralimitando su propia competencia, oprime a los ciudadanos, éstos no pueden negarse a lo que sigue siendo exigencia objetiva del bien común; pero debe permitírseles defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, conservando, sin embargo, los límites que la ley natural y evangélica trazan... Es necesario

*un estatuto positivo de Derecho que organice una repartición oportuna de las funciones y los órganos del poder... Velen los dirigentes para no entorpecer las agrupaciones familiares, sociales, y culturales, las corporaciones y organismos intermedios y, lejos de privarles de su acción legítima y constructiva, procurarán más bien favorecerla de una manera ordenada. En cuanto a los ciudadanos individualmente o en forma de asociación, tengan cuidado de no atribuir a la autoridad pública de un poder excesivo... Es inhumano que la autoridad política degenera en formas totalitarias o dictatoriales que menoscaban los derechos de las personas o de los grupos sociales"*²⁹

*"La prosecución del bien común constituye la razón misma de ser de los poderes públicos, los cuales están obligados a actuarlo reconociendo y respetando sus elementos esenciales y según los postulados de las respectivas situaciones históricas... La autoridad que se funda tan sólo o principalmente en la amenaza o el temor de las penas o en la promesa de premios, no mueve eficazmente al hombre a la prosecución del bien común; y aun cuando lo hiciera, no sería ello conforme a la dignidad de la persona humana... La autoridad, como está dicho, es postulada por el orden moral y deriva de Dios. Por lo tanto, si las leyes o preceptos de los gobernantes estuvieren en contradicción con aquel orden... no tendrían fuerza para obligar en conciencia... Así lo enseña Santo Tomás:... Hay que decir que la ley humana, en tanto tiene razón de ley, en cuanto es conforme a la recta razón, y según esto es manifiesto que deriva de la ley eterna. Por el contrario, cuando una ley está en contradicción con la razón, se llama ley injusta, y así no tiene razón de ley; sino que más bien se convierte en un acto de violencia"*³⁰

Finalmente, queremos insistir que frente a la siempre posible existencia del abuso del poder, el orden jurídico debe establecer en sus fórmulas, con claridad meridiana, las esferas de poder tanto de los particulares, como de los órganos del Estado, para que en equilibrio y armonía pueda realizarse este sistema de frenos y contrapesos, que garantice, en última instancia, el disfrute pleno de los derechos de cada integrante de la sociedad y la realización conjunta de la comunidad. Únicos sustentos de la dignidad de la persona del hombre.

²⁹ PAULO VI, Constitución Pastoral *Gaudium et Spes*.

³⁰ JUAN XXIII, Encíclica *Pacem in Terris*.

CAPÍTULO IV LA JUSTICIA

En este capítulo vamos a tratar de develar uno de los conceptos centrales que hacen a la existencia misma del Derecho. Al valor justicia le hemos atribuido no sólo trascendencia en cuanto al desarrollo del orden jurídico, sino que también lo encontramos como motor de la evolución humana. Así, la justicia trasciende a la ciencia jurídica, para colocarse en un ámbito más comprensivo. La búsqueda de lo justo es el motor de la historia, no sólo lo justo dentro de aquellas situaciones que tienen relevancia para el derecho, sino también lo justo en todas aquellas relaciones posibles entre los hombres. Cuando hablamos de los rasgos del orden jurídico, dijimos —entre otros caracteres— que éste era limitado, lo que implica que no es la única norma de vida; sin embargo, el valor justicia supera los estrictos límites de la ciencia jurídica, para instalarse como motor de la evolución de la historia de la humanidad. Lo que implica que la justicia va a gobernar la evolución total del hombre. No sólo en aquellas conductas que tienen relevancia para el orden jurídico, sino también sobre todas aquellas que le son ajenas.

Para ejemplificar, observemos la evolución de la mujer con respecto al lugar que ocupa en la sociedad. Muchos aspectos de esta evolución son relevantes para el orden jurídico, verbigracia, los derechos políticos, o igual remuneración por igual tarea; en cambio, otros aspectos de la misma, no tienen relevancia alguna para el derecho, como puede ser la relación de los cónyuges con respecto a las obligaciones domésticas. Sin embargo, ambas situaciones son el resultado de la evolución motorizada por la búsqueda de la justicia, que permite una mayor realización de lo justo en las relaciones sociales. En nuestro ejemplo, una situación más justa de la mujer con respecto a su entorno.

En este capítulo, trataremos sobre la justicia en relación con el orden jurídico.

I. LA IDEA DEL DERECHO

Hemos hablado de los valores, como entidades ideales a realizar por el orden jurídico. En el valor justicia habíamos encontrado la base sobre la que se estructura el orden jurídico.

La cuestión que primero debemos plantearnos es si el hombre al crear el Derecho (acto que corresponde a la capa consciente de la *psiquis*) lo hace en forma arbitraria, conforme él crea o le plazca, o por el contrario se encuentra vinculado de manera más o menos observable, a determinado desarrollo y orientación de su orden jurídico.

*"Los entes ideales abarcan aquella parte de la realidad que es sólo asequible a la razón, a diferencia de la realidad material, que además de la razón requiere el auxilio de los sentidos, y de la psique propia, que igualmente además de la razón necesita la intervención de la introspección. Siendo realidad, los entes ideales son objetivos, lo que quiere decir que son trascendentes a la razón que únicamente los capta, pero no los inventa. Con miras a esta objetividad es posible controlar las afirmaciones de la razón como acertadas o desacertadas"*¹.

Los valores que el hombre devela pero no crea, son los que determinan la evolución del orden jurídico. Es decir, el hombre capta por intermedio de su conciencia jurídica los valores, a cada momento con mayor plenitud, luego al hacerlos conscientes, es su propia actividad que los realiza e interpola en su realidad cotidiana. El descubrimiento de un valor exige adecuar nuestra conducta a él y esforzarnos para lograr su plena realización.

*"La cuestión básica es, pues, la de si existe algo así como un derecho de valores y leyes morales identificables por el hombre, que determinen su obrar y constituya una parte del mundo en que vive... El espíritu humano actúa creadoramente en la formación del derecho, pero no arbitrariamente. Es evidente que sigue determinadas conexiones que se le presentan en los problemas. Esto no es mera impresión del observador que reconstruye a posteriori la realidad jurídica. El juez que decide un proceso no tiene la impresión de haber dado una solución cualquiera, sino la de haber ofrecido la prefigurada por la cosa misma"*².

El problema de la idea del Derecho se refiere a la finalidad y a los objetivos éticos de la configuración del orden jurídico, existe aquí una pro-

¹ GOLDSCHMIDT, *Introducción Filosófica al Derecho*, Depalma, Buenos Aires, 1980, pág. 391.

² COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 106.

funda conexión entre los valores y el Derecho. Es el ámbito donde el orden jurídico penetra en el eterno mundo de los valores.

Esta concepción comienza con la filosofía platónica. Como ya hemos visto, para Platón las ideas son el ser propio, las cosas de la realidad se nos presentan como remedos de las esencias. Entre las ideas también se encuentran los valores: lo justo, lo bueno, lo bello, lo santo, etcétera. El hombre es portador de un recuerdo indeleble de las esencias, porque las ha contemplado en su plenitud.

La idea del Derecho se refiere a la adecuación del orden jurídico a esos valores éticos, que actúan como orientadores de la estructuración social. De lo que se infiere que el contenido del Derecho debe estar impregnado por los valores descubiertos por la *psiquis* humana.

El Derecho, en base a lo dicho, será: la ordenación de la razón a la justicia (el valor justicia es entendido aquí como valor comprensivo de todos los valores a realizar en el orden jurídico).

Esta concepción no es ni ha sido pacíficamente aceptada. Desde el primer momento debió sufrir los embates de las corrientes relativistas, escepticas y nihilistas.

Estas concepciones, *"Desde antiguo se presentan como una doctrina desenmascaradora. Los sentimientos morales de valor, la supuesta aspiración a la justicia, no son más que un engaño y, en el mejor de los casos, un autoengaño subjetivamente creído. En realidad no existen tales sentimientos y aspiraciones..."*³.

Así, ya en *La República*, Platón nos refiere este planteo, en la voz de Trasímaco.

"—¿A qué viene, Sócrates, toda esa palabrería? ...responde tú mismo y dí qué entiendes por justicia. Y no vayas a responder que es lo conveniente, lo útil, lo ventajoso, lo lucrativo, o lo provechoso. Responde con claridad y precisión, porque no estoy dispuesto a tolerar semejantes pampas..."

"—Trasímaco, no te irrites contra nosotros, si Polemarco y yo hemos fracasado un tanto en nuestra discusión, convéncete de que no ha sido intencionalmente..."

"—Por Hércules —exclamó—. He aquí, una vez más, la acostumbrada ironía de Sócrates. Bien sabía que no habrías de responder y previene a mis compañeros de que echarías mano de tus pretextos y mañas de siempre para no contestar cuando te preguntara."

³ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 110.

"—En efecto, Trasímaco —dijo yo— eres sutil, y bien sabes que si preguntarás a cualquiera de qué se compone el número doce y al preguntarle añadirías: cuidado, amigo, no digas que es dos veces seis, ni tres veces cuatro, ni seis veces dos, ni cuatro veces tres, porque no aceptaré ninguna de semejantes necedades, es claro, pienso yo, que nadie contestaría a una pregunta así formulada...

"—¿Es eso lo que pretendes hacer? —dijo— ¿Vas a darme por respuesta una de las que yo he rechazado?

"—No sería extraño —contesté— si me pareciera apropiado después de reflexionar.

"—Y si yo diera una definición de la justicia diferente de las anteriores y mejor que todas ellas —replicó— ¿qué sucedería? ¿A qué pena habrías de someterte?

"—¿A qué otra pena —contesté— sino a la que merece sufrir el ignorante, o sea, la de aprender de aquel que es más sabio? De esa pena me considero digno.

"—He aquí la sabiduría de Sócrates —dijo— no querer enseñar e ir aprendiendo de unos y otros sin agradecérselo a nadie.

"—Tienes razón —contesté— en lo de aprender de los demás, Trasímaco; pero te equivocas en afirmar que no lo agradezco, pues pago con lo que puedo, y no puedo hacerlo más que con aplausos, pues carezco de dinero...

"—Escucha, pues —dijo—, sostengo yo que la justicia no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte... Y ¿no dicta cada gobierno las leyes que le conviene? ¿El democrático, democráticas; el tiránico, tiránicas, y así los demás? Establecidas las leyes, los gobernantes demuestran que para los gobernados es justo lo que a ellos les conviene. ¿No castigan a quienes violan esas leyes como culpables de una acción injusta? Tal es querido amigo mi pensamiento: en todas las ciudades, la justicia no es sino la conveniencia del gobierno establecido. Y éste, de una u otra manera, es el que tiene el poder. De modo que para todo hombre que razone sensatamente, lo justo es lo mismo en todas partes: lo que le conviene al más fuerte" ⁴.

Esta posición de Trasímaco ha sido reiteradamente utilizada. Su última y más perfecta expresión corresponde al jurista Hans Kelsen, en su obra *Teoría Pura del Derecho*.

Trasímaco explicita una corriente que tendrá suma influencia hasta nuestros días. La justicia para esta concepción es lo que le conviene al más

⁴ PLATÓN, *La República*, cit., pág. 110.

fuerte. A partir de ello, el Derecho es un instrumento del poder. La norma puesta por el poderoso, obliga al súbdito y permite al titular del poder la comisión de todo tipo de crímenes sin que por ello sea perseguido (conf. Platón, *La República*, 343a - 344d).

Esta concepción es una verdadera claudicación, aquí el Derecho carece de sentido (conf. Rousseau, *El Contrato Social*, Libro I, Cap. III). Todo se encuentra sujeto a la fuerza que ejerce el poder. Las concepciones citadas reconocen la existencia del poder como algo palpable, accesible a un verdadero conocimiento científico. Existencia que se concreta en su eficiencia, que es doblegar efectivamente la voluntad de los súbditos. En cambio, niegan intervención alguna a las ideas morales del Derecho (idea del Derecho), en la configuración del orden jurídico, por la simple razón de ser inexistentes.

II. DEFINICIÓN DE JUSTICIA

Pretender definir a la justicia es una tarea compleja. "*Mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara*" ⁵. A esta tarea se han consagrado innumerables talentos y esfuerzos, sin que el éxito los acompañara. Sin embargo, vamos a ceder a la tentación de proponer una definición de la justicia.

En una primera aproximación que hagamos al concepto de la justicia, observamos que ésta se encuentra profundamente enlazada con otro concepto, el de la igualdad. La justicia en su más elemental y simple expresión implica una profunda vocación a la igualdad. Cualquiera de nosotros no dudaría en acusar de injusta una conducta que no trate de igual manera a aquellas personas que en iguales situaciones han asumido una conducta igual.

El primer planteo que surge de la justicia es tratar igual casos iguales, lo que implica necesariamente, tratar de manera desigual casos que son desiguales.

Ya que, igualar aquello que naturalmente es desigual, produce, como resultado de esa operación, una desigualdad aún mayor (*vid.* Cap. II, Igualdad).

Ahora bien, como hemos dicho (Cap. II), estrictamente no existen dos situaciones iguales, ni dos contratos iguales, ni dos hombres iguales, etcétera. Por lo que, para poder avanzar en este aspecto, debemos precisar el concepto de igualdad. A tal efecto recurrimos a Radbruch, y él nos dice:

⁵ BORGES, J. L., "*Ficciones*" *Obras completas*, Emecé, Buenos Aires, 1974, pág. 453.

"La igualdad es siempre una abstracción desde un punto de vista de una desigualdad dada". Por lo que, si la desigualdad que nos interesa es la altura de cada persona, y dividimos las distintas categorías cada veinte centímetros, podemos afirmar que una mujer de cincuenta años, soltera, con domicilio en la provincia de Catamarca, que mide un metro sesenta y ocho centímetros, es igual a un hombre, de treinta años, domiciliado en la Capital Federal que mide un metro sesenta y siete centímetros. En este caso, obviamos todas las características personales de cada una de las personas sujetas a nuestra observación, con excepción del aspecto que nos interesa para plantear la igualdad o la desigualdad, tal es la altura del sujeto, y a partir de allí, podemos afirmar que estas personas son iguales, en razón que ambas miden entre 1,60 y 1,80 metros.

De la misma manera, si lo que nos interesa es el color de los ojos, podemos afirmar que dos personas son iguales, porque ambas tienen ojos negros, sin detenernos, en su sexo, en su estado civil, su extracción social, su edad, etcétera.

De lo dicho, podemos inferir que la igualdad planteada no es absoluta, lo que naturalmente no se da en esta materia, por lo que siempre es relativa en consideración a las circunstancias que rodean al hecho concreto.

Hemos dicho que el primer mandamiento de la justicia es tratar igual casos iguales. Pero, ¿de dónde debe surgir este patrón objetivo de igualdad? o, lo que es lo mismo, ¿de dónde deben surgir las diferencias que autoricen y legitimen un trato desigual? Para que la justicia no se transforme en un vehículo que, tras una igualación arbitraria, tome su realización en una absurda injusticia. Ejemplifiquemos. Hasta las elecciones presidenciales de 1952, en nuestro país, la mujer no tenía derecho al voto. En esta situación, se daba un aparente cumplimiento del concepto que hemos dado de justicia: tratar igual a los iguales en situaciones iguales. La mujer argentina no votaba, y ninguna mujer lo hacía, es decir, la legislación vigente trataba igual a las mujeres, a todas las mujeres, sin ningún tipo de excepción. Sin embargo, el sexo no tiene relevancia alguna para determinar por sí el goce de los derechos políticos.

Algo falla en esta definición que permite un tratamiento desigual allí donde la naturaleza no lo ha puesto. Y aquí encontramos el centro del problema, en la naturaleza. De ella deben surgir los aspectos que permitan plantear una desigualdad.

De la propia naturaleza de la cosa surge el trato desigual que el Derecho determina, con respecto a una persona capaz y una incapaz, por ejemplo, en la celebración de un contrato. Ya que, mediante el instituto de la capacidad, se pretende lograr un trato desigual en la relación jurídica, como reflejo del que naturalmente se da, para obtener un resultado iguali-

tario, al tratar de manera desigual aquello que en la naturaleza se da como desigual.

Otro tanto ocurre con la relación laboral, pretender igualar al empresario con el trabajador es inicuo, porque redundará en una acumulación mayor de poder en cabeza del empresario y, en estas circunstancias, el trabajador se encontrará sometido a las decisiones arbitrarias de su empleador. De aquí surge, por ejemplo, el principio acuñado por el derecho del trabajo: *in dubio pro operario*, que simplemente determina que mediante la aplicación de este principio el empresario tiene mayores cargas en cuanto a la prueba de lo que afirma, a diferencia del trabajador, que se le exime de una acabada probanza de sus dichos, esto es así, porque el trabajador se encuentra durante toda su relación laboral, en una clara desigualdad con respecto a su empleador.

También resulta de la propia naturaleza un tratamiento distinto en el caso de drogadictos, ebrios, dementes y, en general, cualquier persona que en virtud de una alienación pasajera o permanente, esté en condiciones de otorgar actos contrarios a sus intereses y sujetos por tal motivo a cualquier tipo de explotación.

Del mismo modo no puede ser tratado de igual manera aquel que por razones sociales, económicas, de instrucción, etcétera, se encuentra a merced de otra persona, lo que en síntesis significa que no puede tratarse igual, en el caso concreto, a aquella persona que detenta poder y a la que está sujeto a él. Porque, una obra con absoluta libertad, y la otra tiene su esfera de acción, como mínimo, muy limitada.

Nuestro derecho civil tiene importantes construcciones jurídicas con respecto a estos temas que estamos tratando. El artículo 1197 del Código Civil dice: "Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma". Sin embargo, pese a lo estricto de la norma transcripta, en el mismo Código se establecen las circunstancias que permiten apartarse de las prescripciones establecidas en los contratos, que de acuerdo al artículo citado, las partes deben someterse de igual manera que ante la ley. Así, el artículo 1071 dice: "El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no pueden constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal al que contraría los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres". Este artículo describe lo que la doctrina dio en llamar la teoría del abuso del derecho. En el artículo 1198 nuestro Código dice: "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando

con cuidado y previsión. En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si la prestación a cargo de una parte se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato. En los contratos de ejecución continuada la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos. No procederá la resolución si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora. La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato". Aquí, se establecen los principios de la teoría de la imprevisión. Y, por último, el artículo 954: "Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación. También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos un ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción operará a los cinco años de otorgado el acto. El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el demandado al contestar la demanda". En este artículo se establecen los extremos que nuestra legislación positiva exige para que se configure lo que la doctrina llama lesión objetiva.

Estos artículos, que serán estudiados en profundidad en la materia correspondiente, los citamos aquí, porque la ley, en concordancia con el valor justicia, pretende garantizar, mantener o restablecer la igualdad en aquellas situaciones en que ha sido violada, aun frente a actos jurídicos, que formalmente son impecables. En este aspecto es notorio el esfuerzo de la legislación, que aun ante contratos celebrados inimpugnables desde su aspecto formal, pretende descender el velo de las formas jurídicas y llegar al fondo de la cuestión, y prefiere dejar sin efecto las formas a legitimar una desigualdad.

El ejemplo más común que ocurrió en nuestro país con respecto a estas cuestiones se dio en las décadas del '70 y del '80 con los contratos con cláusulas de actualización monetaria, los que en algunos casos llegó a crear privilegios desmedidos a favor de una parte en detrimento de la otra. Si a la aplicación fría, automática y no siempre razonable de los índices de

actualización monetaria, se le suma la necesidad, inexperiencia o ligereza de la parte afectada, vemos que mantener en forma estricta los términos del contrato es transformarlo en un vehículo de la injusticia, ya que las partes deben ser tratadas de distinta manera porque naturalmente así se dan. No son iguales, ni están en una igual situación el explotador y el explotado. Quizás, el ejemplo más grotesco de lo que aquí enumeramos esté dado por los boletos de compraventa en cuotas de inmuebles urbanos con cláusula de actualización monetaria. Donde se daba la absurda situación de que luego de cada pago el deudor debía más que antes, y que lo adeudado alcanzaba para comprar varios lotes como el adquirido. Esto fue en su momento morigerado por la actuación judicial hasta que finalmente se dictó la ley 23.073, que puso fin a esta situación.

También, nuestro Código Civil trae disposiciones sobre la nulidad de los actos jurídicos con respecto a la actuación de incapaces. Artículo 1040: "El acto jurídico para ser válido debe ser otorgado por persona capaz de cambiar su estado de derecho". El artículo 1041 dispone: "Son nulos los actos jurídicos otorgados por personas absolutamente incapaces por su dependencia de una representación necesaria". El artículo 1042 dice: "Son también nulos los actos jurídicos otorgados por personas incapaces en cuanto al acto, o que dependiesen de la autorización del juez, o de un representante necesario". Por último, el artículo 1045 nos dice: "Son anulables los actos jurídicos, cuando sus agentes obraren con una incapacidad accidental, como si por cualquier causa se hallaren privados de razón, o cuando no fuere conocida su incapacidad impuesta por la ley al tiempo de firmarse el acto o cuando la prohibición del objeto del acto no fuese conocida por la necesidad de alguna investigación de hecho, o cuando tuviesen el vicio de error, violencia, fraude o simulación; y si dependiesen para su validez de la forma instrumental, y fuesen anulables los respectivos instrumentos".

Aquí, al igual que con los artículos transcritos con anterioridad, su estudio se hará en otra materia, nosotros sólo los transcribimos, porque de su simple lectura surge manifiesto el objetivo de la ley: exigir la igualdad de las partes en la celebración de cualquier acto jurídico, bajo pena de anularlo. Y, cuando la naturaleza pone una desigualdad insalvable (v.gr., menor de edad y mayor de edad), recurre al instituto de la representación, para que, con la presencia de un tercero mayor de edad se garantice el efectivo resguardo de los intereses del incapaz.

Hemos citado sólo algunas de aquellas situaciones conflictivas que prevé nuestro ordenamiento positivo ante la violación de la igualdad. Son innumerables las normas que establecen el objetivo de igualdad. Estas citas pretenden mostrar que el orden jurídico persigue de manera inclaud-

cable preservar la igualdad entre los hombres, como clara demostración de la adecuación que el derecho positivo tiene con respecto al valor justicia.

Volviendo al concepto de la justicia decimos que justicia es tratar igual aquellos casos que son iguales y por ende tratar de forma desigual aquellas situaciones que son desiguales.

*"Pero aquí se plantea precisamente la espinosa cuestión de cuál es la escala para decidir cuándo hay que tratar de igual modo y cuándo hay que diferenciar. Esta cuestión no puede resolverse en base a la justicia exclusivamente; la justicia nos deja aquí en un callejón sin salida, pues no tiene sino un criterio negativo de que la diferenciación no debe ser arbitraria; no nos da ninguna respuesta positiva, sino que nos indica la esencia misma de las cosas. La diferenciación, exige la justicia, tiene que tener un fundamento objetivo; tiene que resultar de la cosa misma y no debe ser puesta arbitrariamente por el hombre. La idea del derecho manifiesta aquí su apertura: no nos suministra ninguna valoración cerrada y conclusa. En esta cuestión la idea del derecho nos remite a aquel otro complejo de fenómenos que constituye el segundo punto de partida de nuestra investigación de los prototipos del derecho: la naturaleza de la cosa"*⁶.

Con lo dicho hasta aquí podemos intentar una primera definición de la justicia, entendiéndola como el tratamiento igual de los iguales y desigual de los desiguales tomando las discriminaciones que resultan de la naturaleza misma de las cosas.

A la justicia se la ha definido también desde otros puntos de vista. El notable jurista romano Ulpiano decía que la justicia consiste en la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo *"justitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi"*.

En base a esta definición, podemos preguntarnos: ¿Qué es lo suyo de cada uno? y observamos que la misma definición no nos da una respuesta a la pregunta formulada. Por lo que ésta cae irremediabilmente. No es capaz de darnos una idea global sobre la justicia, tan sólo enumera la acción que debe emprender la justicia, que es, precisamente, dar a cada uno lo suyo, pero volvemos al principio, ¿qué es lo suyo de cada uno?

Sin embargo, creemos que entender a la justicia como una virtud que orienta nuestra conducta y nuestra voluntad a dar a cada uno lo que le corresponde, lo que de sí es suyo, es de suma de utilidad y contiene penetraciones esenciales en el verdadero ser del valor justicia.

⁶ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 130.

⁷ LA PIEZA, Elli, *Historia del Derecho Romano*, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1975.

Por lo que intentaremos, con la invalorable ayuda de Ulpiano, definir a la justicia, agregándole los elementos que permitan determinar qué es lo suyo de cada uno. Definimos entonces, a la justicia como *la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, conforme a su particular naturaleza, a su ubicación en el orden que lo abarca y a su concordancia con el eterno orden del ser*.

Para analizar la definición dada, la vamos a dividir en cuatro partes:

a) Constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo

La justicia no es, necesariamente, la adecuación al derecho puesto, a las normas vigentes en un tiempo y en un espacio dado, sino que es una virtud que orienta y obliga a nuestra conducta a dar a cada quien lo que le corresponde, lo que ya le está asignado. Cabe preguntarse: ¿de dónde surge esta asignación? ¿Quién determina lo que le corresponde a cada uno? En principio, observamos que si pretendemos actuar con justicia, esta asignación no puede surgir de lo que cada uno cree que corresponde asignar al otro y a uno mismo. Necesariamente debe existir alguna forma objetiva de asignar el lugar correspondiente, sino la virtud justicia se transforma en un leal saber y entender de lo que cada uno interpreta, quiere, o le conviene interpretar por ella.

Nada más lejano al concepto que venimos desarrollando que dejar librado la virtud orientadora y ordenadora del orden jurídico a la libre interpretación individual. Por el contrario, entendemos que existen elementos que nos permiten lograr un conocimiento objetivo de la asignación que la justicia determina para cada quien. Y así, esta virtud orienta nuestra conducta y ordena las normas que integran el derecho puesto en base a consideraciones objetivas y de conformidad a ellas. Estas consideraciones objetivas surgen de los siguientes puntos.

b) Conforme a su particular naturaleza

Con esto queremos decir que esa virtud que orienta nuestra conducta frente a los demás y ante las cosas, debe tener en cuenta la particular naturaleza que cada uno y cada cosa tiene.

Por ejemplo, son naturalmente distintas una persona por nacer y una mayor de edad; un demente y uno capaz; una persona que ha recibido instrucción terciaria y aquella otra que es analfabeta. Hemos tomado casos extremos, para ver con claridad, que la naturaleza propia de las cosas determina diferencias entre unas y otras y, estos distintos modos de ser, a su vez, influyen en las asignaciones que el orden jurídico realiza.

No queremos decir con esto que cada persona del ejemplo individualmente tomada sea por su naturaleza distinta de la otra, ya que todos son hombres y, por lo tanto, portadores de la misma dignidad. La distinción entre los hombres comienza cuando las personas se encuentran y entablan algún tipo de relación jurídica. Es allí donde la naturaleza nos dice que existen diferencias entre ambos y que por tal motivo lo que a cada uno le corresponde es también diferente. Un contrato concluido por una persona capaz y otra incapaz, puede ser anulado, sin que por ello se infiera que en nuestro derecho positivo existen distintas "categorías" de hombres. Simplemente el derecho positivo observa las diferencias que surgen de la propia naturaleza. Una persona incapaz no es igual que una capaz, por tal motivo se le otorga esa posibilidad de anular el contrato celebrado, en la medida que sea perjudicial a sus intereses. También observamos esta cuestión en lo que dispone el artículo 954 del Código Civil, donde se podrán anular los contratos cuando una de las partes explote la necesidad, la inexperiencia o la ligereza de la otra. Aquí podemos ver con claridad meridiana que se distingue entre el explotador y el explotado, en la convicción que no son iguales y, por lo tanto, el orden jurídico debe preservar un tratamiento distinto a ambos.

Para completar mejor este concepto, vamos a diferenciar entre la particular naturaleza del hombre, la particular naturaleza de los bienes y la particular naturaleza de las relaciones entre las personas y con las cosas.

La particular naturaleza del hombre trae de suyo el concepto de dignidad de la persona. El hombre es naturalmente una dignidad y como consecuencia de tal exige respeto, tanto del resto de los hombres como del grupo y del orden jurídico. Este concepto de dignidad de la persona del hombre no surge de una convención, de un contrato, o de un acuerdo, tampoco es el descubrimiento de algunas mentes despiertas. Sino que le viene al hombre de su propia forma de ser, de la propia naturaleza de las cosas. Esta exigencia de dignidad nos plantea como primer mandamiento el respeto a la persona del prójimo. Nos dice que debemos tratar al otro como queremos que nos traten. El valor justicia, internalizado en nuestra conciencia jurídica, provoca en los hombres una actitud de profundo rechazo y rebelión frente a cualquier tipo de explotación a que una persona pueda ser sometida, precisamente, porque afecta en su sustento este concepto de dignidad del que todo hombre es portador, por el solo y simple hecho de ser hombre.

De ello, surgen una cantidad de derechos que corresponden al hombre, y que el orden jurídico tan sólo debe tomarlos. Obsérvese, por ejemplo, lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Nacional: "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en

ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas". Y, en el artículo 35 de la Constitución Nacional de 1949 se disponía: "Los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero tampoco amparan a ningún habitante de la Nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de esos derechos que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier tipo de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que serán castigados por las leyes". Luego de la lectura de estos dos artículos transcritos, podemos preguntarnos si se los debemos a la inteligencia y capacidad de nuestros constituyentes tanto de 1853 como de 1949 o, por el contrario, es el resultado de la captación por parte de los individuos que integran la Nación del valor justicia y de la dignidad de la persona del hombre. Obviamente, la instauración de normas de esta magnitud no se debe a inteligencias individuales, a luchas personales. Cuando una comunidad llega a este tipo de conclusiones, estamos en presencia de un nuevo estadio de la evolución, donde el conjunto de la comunidad ha internalizado con mayor precisión el valor de que se trata, y éste exige que adecuemos nuestras instituciones y nuestras vidas a sus pautas.

Por ello, podemos afirmar que este tipo de normas encuentra su fundamento y origen en el valor justicia y en el valor de la dignidad de la persona del hombre.

Para finalizar, la dignidad del hombre nos exige un trato igualitario, no discriminatorio y reconocer en cada hombre, su libertad e independencia. La libertad de culto, la libre elección del domicilio, de la profesión, del estado civil, etcétera, son otros tantos derechos que surgen de la particular naturaleza del hombre, y que ni nosotros, ni los hombres que nos antecedieron los inventaron o los crearon de la nada. Obsérvese que si el hombre no tuviera conciencia de futuro, no cabría hablar del contrato de seguro. Si el hombre no tuviera un sentimiento de autoestima, no cabría hablar del delito de injurias.

Con respecto a la naturaleza de los bienes, debemos aclarar que el concepto de bien lo utilizamos en su sentido más amplio, es decir, abarca tanto objetos materiales como inmateriales.

La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, nos obliga a encontrar la exacta asignación que corresponde a cada cosa de acuerdo a la naturaleza que le es propia.

Para comprender el alcance que damos a esta cuestión vamos a ejemplificar. Cualquiera de nosotros, en el actual régimen de propiedad de la República, puede ser propietario de un vehículo automotor, y despla-

zarse con él. Sin embargo, no por ello puedo contaminar el ambiente, más allá de los límites que determina la correcta aplicación de la tecnología disponible, es decir, puedo utilizar mi coche para lo que fue hecho, para lo que surge de su propia naturaleza, pero no por ello puedo utilizar el escape libre, ya que es una forma de contaminar el ambiente, y porque el automóvil fue hecho para trasladarme y no hacer más ruido del que la tecnología ha podido solucionar.

También, podemos ser propietarios de diversas cosas, y observamos, que no es lo mismo ser propietario de los bienes necesarios para nuestra propia subsistencia (alimentos, vestidos, habitación) que ser propietarios de los medios de producción, sobre estos últimos el Derecho impone día a día mayores limitaciones al ejercicio arbitrario y abusivo del derecho de propiedad, pese a que este derecho fue concebido en sus orígenes como absoluto, exclusivo y perpetuo.

A nadie escapa que resulta ilegítimo la posesión de tierras aptas para la explotación agropecuaria y mantenerlas baldías. Esta valoración es ajena a las disposiciones que en su caso contenga el derecho positivo. Todos sabemos y sentimos que frente al hambre a que se condena a millones de personas, poseer bienes capaces de producir alimentos y no hacerlo es contrario a la justicia. Esto es así, porque la función misma de la tierra —entre otras— que le viene de su propia naturaleza es la de proveer alimentos y abrigo a los hombres, más allá del particular régimen de propiedad que el grupo humano haya creado.

Estos ejemplos nos permiten visualizar que las normas jurídicas establecen derechos y obligaciones de acuerdo a lo que ya cada cosa tiene asignado por su propia naturaleza. La norma no inventa, sino que observa situaciones preexistentes y las ordena de acuerdo a la situación previa.

Observemos, finalmente, la gran cantidad de leyes que en estos últimos años se establecieron con respecto al cuidado y preservación del medio ambiente. Años atrás nadie pensaba en el agua potable, sólo recién cuando el hombre comprendió que no estaba en presencia de un bien inagotable sintió la necesidad de protegerla. Si de la propia naturaleza del bien surge que resulta imposible degradarlo, agotarlo o destruirlo, no tiene sentido hablar de protegerlo, simplemente porque la naturaleza lo dotó de determinadas características que impiden que el hombre lo dañe, sólo cuando de la propia naturaleza surge que es posible dañarlo, surge a su vez la necesidad de dictar normas de protección hacia ese bien.

Por último, la particular naturaleza de las infinitas relaciones que los hombres pueden tener entre sí y de éstos con el grupo, también determina el contenido de la justicia.

La patria potestad, cuyo origen lo encontramos en la más remota antigüedad, corresponde a la misma naturaleza del hombre y a la particular forma de relación que el hombre tiene con sus hijos.

El matrimonio, en el sentido de una plena comunidad de vida es otra forma de relación, que de sí determina la asignación que le corresponde a él y a cada uno de los integrantes.

El contrato de locación, o de compraventa, o de mutuo, son a su vez otras formas que tiene el hombre de relacionarse con otros hombres. Cada una de ellas con sus particularidades propias, que no le vienen por la decisión de cada hombre, ni de una convención, ni de un acuerdo logrado. Estas formas de relación son distintas, porque naturalmente surge la asignación de lo que corresponde a cada situación. No es igual contraer matrimonio que celebrar un contrato de mutuo hipotecario.

También, la relación de los individuos con el Estado tiene particularidades determinadas por la naturaleza misma de la relación. Al Estado, por su propia razón de ser le corresponde la consecución de manera ineludible del bienestar general. En esta búsqueda podrá entrar en conflicto con intereses particulares. Aquí debe ceder espacio el interés individual, sin que por ello se afecte la dignidad presente en cada uno de los individuos. Así, pueden comprenderse los institutos de la expropiación por causa de utilidad pública y el allanamiento, que afectan los derechos de propiedad e inviolabilidad del domicilio.

c) A su ubicación en el orden que lo abarca

En el Capítulo II hablamos del orden y lo definíamos como la posición de cada miembro dentro del ámbito que abarca —ese orden— y con respecto a los otros miembros abarcados.

La justicia, en su constante y perpetua vocación de dar a cada uno lo suyo, no sólo debe conformar sus postulados a lo que corresponde a cada uno de acuerdo a su particular naturaleza, sino también fijar su atención en la ubicación que le corresponde a cada uno dentro del orden al cual se dirige.

A un padre de familia le corresponde —por ejemplo— el ejercicio de la patria potestad, pero además puede ser empleado, locador o locatario, acreedor o deudor, etcétera. De tal manera que la posición de cada uno dentro del orden que lo abarca no es exclusiva ni excluyente, además permite a cada individuo asumir todas las posiciones correspondientes a cada una de sus relaciones sociales, por ello pueden coexistir, pueden darse simultáneamente. Nada obsta ser a la vez: padre, acreedor, deudor, locador y locatario. En cada una de estas posiciones relativas la persona es sujeto

de distintas obligaciones y derechos. Asignaciones éstas que surgen de la relación misma.

Los atributos asignados varían de acuerdo a esa ubicación en el orden. El padre tiene la obligación y el derecho a ejercer la patria potestad. El acreedor tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación debida, etcétera.

Es decir, de acuerdo a la posición relativa que cada uno de nosotros ocupa en el orden de las relaciones sociales, surge lo que nos corresponde en concordancia con esa posición, porque no es lo mismo ser empleado que cónyuge, acreedor que padre, deudor que locador. En cada una y para cada una de las relaciones la justicia pretende dar lo debido a cada uno, en perfecta armonía, con la naturaleza misma de la relación de que se trate, es por ello que se debe prestar suma atención a cada una de las múltiples posiciones que cada uno de nosotros puede asumir en nuestra vida de relación.

De la posición que tengamos, en un preciso momento, surgirán las atribuciones que el orden jurídico debe reconocer, no como arbitraria decisión legislativa, sino como resultado propio de la ubicación que tenemos dentro de esa relación, ya que, insistimos con el ejemplo, no es lo mismo ser acreedor que deudor, por lo tanto, el Derecho debe reconocer, en cabeza de cada quien, las atribuciones que surgen de la propia naturaleza de la cosa, de acuerdo a la ubicación de cada uno en esa relación.

d) Y a la concordancia con el eterno orden del ser

El concepto del eterno orden del ser ha tenido su máximo desarrollo en la teoría iusnaturalista de Santo Tomás, que veía en cada cosa y en cada ente una ubicación previamente determinada y otorgada por Dios, por lo que la justicia, simplemente, debería dar a cada uno según su naturaleza esencial conforme al orden divino de la creación.

De este planteo surgen dos problemas: uno, el origen divino del orden del ser, y el otro es si existe la posibilidad de un conocimiento pleno y acabado por parte del hombre del orden del ser.

Con respecto al primer problema, sobre el origen divino del orden del ser, entendemos que a los fines de este libro resulta innecesario su análisis, por lo que lo obviaremos, ya que en última instancia nos llevaría a la discusión sobre la existencia de Dios. Sin embargo, sin entrar en este terreno, por demás complejo, podemos analizar, e intentar probar la existencia de lo que hemos llamado el eterno orden del ser.

Esta cuestión la comenzamos por preguntarnos sobre cualquier institución jurídica. Una vez determinada la institución que vamos a investi-

gar debemos quitarle las cuestiones particulares que hacen a la realidad concreta en que fue regulada, para observar en esencia a la institución.

El matrimonio, por ejemplo, según el grupo humano de que se trate, será considerado, de muy diferente manera. Su existencia podrá acreditarse mediante constancias de la Iglesia, o por los registros de estado civil y capacidad de las personas. Podrá regularse de una u otra manera los efectos patrimoniales del matrimonio, podrá haber más o menos impedimentos, el vínculo será indisoluble o no; el adulterio podrá ser causal de divorcio, un delito o nada, podrá ser considerado un simple contrato o una institución social, etcétera. Pero si le quitamos las particularidades que corresponden a los intereses, creencias y pareceres vivos en el grupo social de que se trate, veremos la esencia del instituto. En nuestro caso, el matrimonio es esencialmente, la unión de un hombre con una mujer en una plena comunidad de vida.

O, acaso, el matrimonio comienza cuando los contrayentes pasan por el Registro Civil, o la Iglesia, según el caso, o empieza cuando se resolvieron los conflictos patrimoniales que el mismo puede generar. O cuando estamos en presencia de una pareja separada desde muchos años, sin ninguna voluntad de reanudar el vínculo, podemos plantearnos que estamos frente a un matrimonio, más allá de la legislación vigente sobre el divorcio.

Cuando conocemos a un matrimonio, le exigimos que acrediten el vínculo mediante la exhibición de la partida respectiva. O, por el contrario, el matrimonio existe en la misma medida en que existe esa unión de personas de distinto sexo para constituir una plena comunidad de vida. Es decir, un matrimonio, en su esencia, no requiere la presencia de detalles particulares que hacen a las convicciones del grupo en el cual se desarrolle. Habrá entonces matrimonio, ahora, o en cualquier momento histórico que queráramos investigar, cuando a su vez ese varón y esa mujer constituyan una plena comunidad de vida.

La partida de matrimonio, expedida por el Registro Civil es, simplemente preconstituir una prueba. Sirve para acreditar de manera eficiente la existencia del vínculo. Pero nadie puede concluir que a partir de la exteriorización de la voluntad ante el oficial público, se constituye sin más el matrimonio. Porque el sustento único y excluyente del matrimonio, desde todos los tiempos es el amor, que vive y renace cada día, junto con el respeto y la firme convicción de vivir con el otro una plena comunidad de vida.

De lo dicho podemos concluir que el matrimonio, más allá de las particularidades de cada comunidad, tiene un lugar asignado por y en el eterno orden del ser.

La justicia nos exige dar a cada uno lo que le corresponde, el derecho positivo debe adecuarse a esa exigencia, por eso, la legislación debe recoger las particularidades propias que surgen del ser de las cosas. Imaginemos simplemente la siguiente hipótesis: en una sociedad cualquiera, un grupo de desquiciados se encarama en las estructuras de poder —observemos que esta hipótesis, no es tan descabellada— y se determina por vía legislativa la inexistencia del matrimonio, podrá a su vez, eliminarse la esencia del matrimonio que es, como dijimos, el amor y esa voluntad de vivir en común. Obviamente, no. Lo que vuelve a confirmar la existencia de la esencia de cada institución jurídica, más allá de su regulación positiva. Hacia allí debe mirar la justicia.

En otro ejemplo, la quiebra, las facultades de los acreedores pueden consistir en repartirse el cuerpo del fallido, o sólo los bienes de él. Los límites a estas cuestiones estarán dados por el estadio de evolución de la sociedad concreta, en que el drama se desarrolla. Pero en última instancia, este instituto viene a resolver el conflicto social suscitado por la insolvencia de uno de sus integrantes.

La patria potestad tiene su origen en la naturaleza misma del hombre, y en el maravilloso milagro de unir el amor a la reproducción de la especie.

El grupo puede determinar que el padre tiene derecho de vida y muerte sobre el hijo (Roma) o, por el contrario, entender que fundamentalmente es un conjunto de obligaciones que los padres tienen con respecto a los bienes y las personas de sus hijos. Esto, estará ligado al grado de evolución alcanzado por la sociedad, pero de manera incuestionable, la patria potestad surge de la naturaleza humana, y en consecuencia, tiene asignado un lugar en el orden del ser. De lo contrario, tendríamos que considerar, que la patria potestad nos viene de la lucidez de algún remoto legislador, que al igual que el demiurgo la construyó de la nada.

La organización política de las naciones modernas podrá estar dada por una constitución escrita o no, podrá tener la clásica división de poderes o buscar otra forma de evitar el abuso del poder. El máximo órgano judicial podrá tener tres, cinco, veinticuatro o treinta miembros. El Poder Ejecutivo podrá ser unipersonal o colegiado, etcétera, ya que en última instancia, lo que legitima la existencia del Estado es la promoción del bienestar general, no particularidades que surgen del grupo. De ello se colige, que el Estado tiene de sí una ubicación en el orden del ser. La estructura que asuma en un momento histórico concreto, debe siempre respetar esa asignación que le viene de suyo, de lo contrario, el Estado podrá ser formalmente impecable, dictar leyes todos los días, de acuerdo a las formas establecidas o no, pero seguro, que el Estado que no persigue la promoción del bienestar general es ajeno a la justicia.

En resumen, podemos afirmar que cada una de las particulares asignaciones que el orden puesto en una sociedad concreta otorga, deben estar adecuadas y en armonía a lo que surge del eterno orden del ser y de acuerdo al estadio de evolución que corresponde, para que a su vez ese orden en las relaciones sociales esté ordenado por la justicia.

El segundo punto al que nos referíamos, era sobre la posibilidad de conocer en plenitud el eterno orden del ser.

Sobre este tema hablaremos en el capítulo siguiente ("Naturaleza de la cosa"), sin embargo, para concluir esta definición de justicia, adelantamos nuestra opinión. El conocimiento pleno del orden del ser es sumamente problemático; el hombre tan sólo logra penetrar a pequeñas porciones de él. De esto surge la inevitable necesidad de elegir, de decidir qué tendencias deben prevalecer en la sociedad y cuáles no. Esta decisión ineliminable en el hombre, porque depende, precisamente, de la limitación apuntada, en el sentido de poder aprehender cabalmente el eterno orden del ser, cuyo conocimiento, además, se encuentra indisolublemente ligado a la evolución. Por ello, el hombre descubre el velo de apenas porciones del eterno orden del ser. El conocimiento de esas pequeñas realidades esenciales, le permiten avanzar a tientas por el camino de la evolución, que a su vez permite ir penetrando a nuevas porciones del orden del ser.

En resumen, nuestra propia incapacidad para penetrar en la plenitud del eterno orden del ser, no puede impedirnos a su vez el conocimiento de su propia existencia. Ya que negar su existencia, a partir de la dificultad que presenta su conocimiento parcial y la imposibilidad de su aprehensión global, equivaldría a negar la existencia de las estrellas que nuestros sentidos y variantes tecnológicas no puedan captar.

Por lo dicho, reiteramos, que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde conforme a su particular naturaleza, a su ubicación en el orden que lo abarca y a su concordancia con el eterno orden del ser.

III. CONTENIDO MORAL DEL DERECHO

Al hablar del contenido moral del Derecho, debemos volver al tema de la idea del Derecho.

"Cuando son los fines morales del Derecho los protagonistas de la discusión, se ha buscado el prototipo y modelo moral de todo Derecho: éste es el problema de la idea del Derecho. Por lo que hace a la materia del Derecho se ha buscado un orden natural de la convivencia humana, que fuera reconocible en la vida social misma. Este problema ha sido planteado del modo más profundo por la filosofía social cristiana, que vio

en la vida social y en sus instintos una realización de las ideas divinas, del orden de la creación impuesto por Dios al mundo. Pero también al margen de la filosofía cristiana se ha suscitado la cuestión. La idea de un orden naturel, presentada por la ilustración en el terreno de la economía, se encuentra en la misma dirección. En la jurisprudencia práctica ese mismo punto de vista aparece constantemente bajo la más modesta denominación de naturaleza de la cosa”⁸.

El contenido moral del Derecho está dado por los valores que capta la conciencia jurídica, y a partir del tránsito de la capa inconsciente a la consciente es que se hacen conscientes los valores que penetran en el hombre por su personalidad profunda. Estos valores son conocidos juntamente con la exigencia de vivir conforme a ellos.

Volvemos al tema de los valores. “Los valores con conceptos universales. Como tales ellos entran en la magna controversia entre el nominalismo, el realismo y el realismo moderado. De ahí resulta que tan equivocado sería afirmar (como lo hace el nominalismo) que sólo los valores existen, pero no lo valioso en la realidad, como sería equivocado sostener (como lo hace el realismo) que lo valioso existe en estado de universalidad en la realidad: lo que pasa es que lo que las ideas de los valores nos presentan en estado de universalidad, no existe fuera del espíritu en ese estado de universalidad sino que existe en estado de individualidad”⁹.

“Los bienes finitos o valores son realmente esencias concretas, las cuales, como tales, también pueden ser abstraídas de su realización individual y contingente y concebidas como valores abstractos, en sí y, en esta forma, se presentan realizando en toda su pureza la esencia del valor. Así de los actos justos reales —existentes o posibles— abstraemos la noción o esencia de justicia. Y los actos humanos para ser justos deben ajustarse a la esencia de justicia. Tal esencia no existe realmente sino en los actos justos; pero en sí misma, como esencia abstraída de lo real, es también ella real, sus notas constitutivas son reales; bien que no sea real el modo universal y abstracto con que se la concibe y que por eso no se predica de los actos u objetos concretos. Los valores así concebidos son, pues, reales en lo que ellos expresan, en las notas constitutivas de la esencia valiosa, bien que no lo sean en el modo abstracto o universal, puramente mental, con que son expresados por el intelecto”¹⁰.

⁸ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 107.

⁹ GOLDSCHMIDT, *op. cit.*, pág. 470.

¹⁰ DERISI, *Filosofía de la Cultura y de los Valores*, Emecé, Buenos Aires, 1963, pág. 162.

“Los valores, al menos los valores naturales como la justicia, si bien los captamos en estado de universalidad mediante la razón, de ningún modo son producto de la razón y, por ende, a su merced”¹¹.

Hemos planteado opiniones de autores que coinciden en lo que venimos diciendo sobre la cuestión de la existencia de los valores, sin embargo, no por ello debemos dejar de reconocer que las teorías nihilistas y relativistas contienen “penetraciones esenciales en el ser del Derecho; su error consiste propiamente en que absolutizan verdades parciales y pasan por alto las tendencias morales supremas del Derecho. Todo derecho positivo contiene también una seguridad del poder y, por lo tanto, expresión de relaciones de poder. Todo derecho positivo está en peligro de servir a intereses de clase. Y sucumbe además a menudo a ese peligro. Los intereses de clase y la conciencia de clase no son sólo obstáculos difíciles de superar en la imposición de la regulación justa, sino que, además, constituyen un peligro de desviación del sentimiento jurídico y resultan así un riesgo para la jurisprudencia misma”¹².

Ocurre que simplemente el conocimiento de los valores no posee la exactitud de los métodos científicos naturales.

La Tierra gira alrededor del Sol, este fenómeno se realiza, más allá de la opinión y decisión de los hombres. Éstos no son parte alguna. Los fenómenos naturales se realizan a sí mismos. El hombre podía creer que la Tierra estaba inmóvil, que era plana, y luego de ella el abismo. Lo podían creer, asegurar y argumentar. Sin embargo, aunque todos los hombres estuvieran convencidos de la existencia real de ese error, la Tierra giraría alrededor del Sol, y sería tal cual es. No ocurre lo mismo con los valores, tanto para su conocimiento como para su realización.

Para lograr poseer el conocimiento de un valor, no podemos obviar la actividad subjetiva, es decir, la actividad concreta de cada uno de los hombres, que capta o devela un valor específico, a partir de su dimensión espiritual.

“Ciertamente que la intelección moral no puede nunca despojarse totalmente de la vivencia subjetiva (pues esta vivencia es la única vía de acceso que tenemos para llegar al mundo de lo moral), cierto también, consiguientemente, que una proposición acerca del contenido de valores morales no alcanzará nunca la exactitud del conocimiento científico natural y que la importancia de la ecuación personal será siempre considerable; pero siempre será posible enunciar un grado de verdad sobre el

¹¹ GOLDSCHMIDT, *op. cit.*, pág. 470.

¹² COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 116.

*contenido de los diversos valores morales. En otro caso sería completamente imposible e inimaginable una comprensión entre hombres, especialmente de diversas culturas. En última instancia, también en este terreno de lo moral se pone de manifiesto, como en el de la percepción sensible, que, en líneas generales, es el mismo ámbito de ser el que se abre a todos los hombres. Tenemos pues que partir del hecho de que los diversos valores morales, tal como se nos dan en la conciencia moral, son descriptibles con cierto grado de corrección objetiva"*¹³.

Otro aspecto al que también podemos considerar conflictivo para esta concepción objetiva de los valores, tanto para su conocimiento como para su realización, es la existencia de diversos valores que nos exigen adecuar nuestra conducta a ellos. Como consecuencia de las limitaciones propias de la vida humana, esto resulta imposible. Nadie puede realizar la totalidad de los valores en su vida, por ello, se resigna a realizar algunos.

*"Nos vemos así obligados a elegir entre ellos—los valores— a decidimos por uno de ellos. Este es un hecho que no puede negarse. La decisión moral es ineliminable de la vida moral. Pero sería falso describir la situación como si fuera nuestra decisión la que da al valor su valor. No se trata de eso. El que tengamos que decidir se debe a la limitación de nuestras vidas; no podemos realizar homogéneamente todo el reino de los valores, no podemos resumir en nuestra acción a la humanidad entera. Nuestro destino es la limitación. Pero precisamente por eso siguen conservando su valor los valores por los cuales no nos decidimos"*¹⁴.

No cabe duda alguna de que la valentía, la fuerza, la humildad, la sabiduría, el amor al prójimo, etcétera, son valores que el hombre ha descubierto, pero no podemos realizarlos a todos en nuestra vida individual, por eso debemos decidir cuáles van a prevalecer y orientar y dirigir nuestras vidas. Sin embargo, entendemos que los valores que hemos llamado puros, no se excluyen entre sí, por el contrario, la mejor realización de uno implica una más completa aprehensión de los otros. Si una sociedad logra una mayor seguridad para sus integrantes, esto redundará en una mayor libertad, y por ende, en una mejor captación del valor justicia.

En resumen, no es el hombre en su condición individual el que realiza el amplio espectro de valores que se abre a nuestra decisión. Es la humanidad la que realiza la totalidad de los valores que la sociedad de que se trate ha develado, mediante la suma total de las decisiones individuales.

¹³ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 121.

¹⁴ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 123.

Por último, en cuanto a la realización de los valores, debemos decir que el hombre es el punto de penetración de los valores en la realidad. Lo justo no se realiza con la necesidad y el fatalismo con que ocurren los fenómenos de la naturaleza. La justicia requiere de los hombres para su realización. En la lucha constante del hombre para intercalar en su terrena realidad los valores develados, éstos se realizan.

*"Otro tanto ocurre con los entes ideales exigentes. La belleza se pone en evidencia en una obra humana de arte, la prudencia en una conducta humana, etcétera. La concepción contraria que predica la autoejecutoriedad de los entes ideales, es a todas luces errónea y sumamente peligrosa: creer que la justicia se va a realizar en esta tierra, durmiendo la siesta, no resiste el más mínimo análisis, y constituye una creencia tan cómoda como perjudicial... Ahora bien, el hecho de que la realización material y psíquica de los entes ideales requiere un acto humano, ha dado lugar a otra teoría opuesta a la de la autoejecutoriedad de los entes ideales, pero, casi tan equivocada como aquélla: me refiero al relativismo. El relativismo, en efecto, enseña que los valores carecen de carácter objetivo, es decir, real, y que son creados por el acto humano... Inferir del hecho de que la eficacia de la solución justa requiere la actividad del juez, que es el juez quien inventa la solución justa, no merece mayor aplauso que inferir del hecho de que la eficacia de las reglas matemáticas o físicas requiere los cálculos de matemáticos y físicos, que son ellos los que crean aquellas reglas. Y ambas inferencias a su vez no son dignas de mayor elogio que una tercera: inferir del hecho de que algo material debe hacerse consciente para que cobre existencia para mí, el hecho de que yo creo lo material al hacerlo consciente"*¹⁵.

Para concluir, afirmamos que el contenido moral del Derecho son los valores: el orden, la paz, la seguridad, la igualdad, la libertad, en última instancia, la justicia.

IV. EL VALOR JUSTICIA

Ya, en la antigüedad, los hombres discutieron y analizaron el concepto del valor justicia, pretendiendo delimitar su contenido y conocer su esencia.

En esta parte del libro, haremos una breve referencia histórica. Nuestra reseña comienza en la antigua Grecia.

¹⁵ GOLDSCHMIDT, op. cit., pág. 370.